

preparada por decisiones particulares, es solemnemente afirmada sólo por los justinianeos; a ellos pertenece también la máxima "in lege Aquilia et levissima culpa venit" (D. 9, 2, 44 pr.), conforme con la tendencia a graduar la culpa, de la cual se tratará a propósito del daño contractual (p. 429).

Desde el punto de vista de la legitimación de la acción, el derecho justiniano extiende los estrechos límites impuestos por el derecho clásico. La ley la atribuía, como se ha visto, al dueño (*herus*) de la cosa destruida o deteriorada; entre las extensiones que resultan del Digesto, por lo menos una, la que se da en favor del acreedor pignoraticio, es ahora considerada justiniana por consenso unánime de los romanistas; la opinión muchas veces sostenida en la doctrina de que sea igual el origen de las extensiones operadas en favor del usufructuario y del locatario, tiene por sí grandes probabilidades.

§ 3. LOS ACTOS ILÍCITOS DEL DERECHO PRETORIO (CUASI DELITOS)

Entre los innumerables actos que el pretor ha considerado ilícitos y sancionado con acciones penales *in factum conceptae*, pueden recordarse aquí sólo los principales en cuanto no se discorra sobre ellos más convenientemente en otra parte²². Y antes que nada corresponde mencionar los que han merecido (no sabríamos decir cómo) el honor de ser elegidos en las *Res cottidianae* y por los justinianeos como paradigmas de los cuasi delitos.

1) La acción *de effusis et deiectis* se otorga contra el *habitor* de un edificio, del cual haya caído de cualquier modo a la calle o en otro lugar público, alguna cosa que haya causado daño, por el doble valor de las cosas destruidas o por la doble disminución de valor de las cosas deterioradas. Si un hombre libre es herido, la acción se concede, por evidente analogía con la *actio iniuriarum*, *in quantum bonum aequum iudici videbitur*; si ha muerto, nace una acción popular por la suma fija de 50.000 sestericios. En el derecho clásico, no se requiere un especial elemento subjetivo;

²² Por eso omitimos en este punto, por ejemplo, las *actiones doli y metus causa* (ps. 117 y ss.).

pero en el justiniano, y como consecuencia de una evolución cumplida en la época posclásica, se exige la culpa²³.

2) La acción *de posito et suspenso* corresponde también contra el *habitor* de un edificio cuando sobre un balcón o techo se ha colocado o suspendido alguna cosa cuya caída podría ocasionar daño a las personas. La acción es popular, y da lugar a una pena fija de 10.000 sestericios; también aquí la responsabilidad es objetiva para los clásicos, y el límite de la culpa lo introducen los justinianos en D. 9, 3, 6 § 2 (BETTI).

3) Colocados en este camino de la responsabilidad eventualmente contraída por el hecho de otro, los autores de las *Res cottidianae* han incluido entre los cuasi delitos también la responsabilidad del conductor, del posadero y del encargado del establo por el hurto cometido en perjuicio de los pasajeros y clientes; sobre la acción especial, que para el derecho clásico es una simple adaptación de la *actio furti*, cfr. p. 413.

4) Como cuasi delito está construido, en los diversos lugares que vienen a parar en el célebre texto de las *Res cottidianae* (D. 44, 7, 5 § 4; 50, 13, 6; I. 4, 5 pr.; cfr. p. 327), también el caso del *iudex qui litem suam fecit*. El sentido originario de la expresión era, quizá, el de apropiación indebida de la cosa controvertida, en un tiempo en el cual el juez la habría tenido en custodia hasta la sentencia (cfr. p. 130, n. 8); pero en la época clásica se llama con este nombre el hecho del juez que "*dolo malo in fraudem legis (litigatoris?; BESELER) sententiam dixerit*" (ULPIANO, D. 5, 1, 15 § 1); frase ésta tan técnicamente perfecta como para tener toda la apariencia de haber sido trascrita del Edicto. Una nueva doctrina, que consideraba ejercible la acción contra el juez que por negligencia hubiese juzgado mal, fué expuesta en las *Res cottidianae* (obra, como sabemos, posclásica) y es preferida por JUSTINIANO; pero parece que ya desde la época republicana hubiese encontrado alguna aceptación entre juristas imbuídos de filosofía griega²⁴.

Fuera de los casos definidos como cuasi delitos, recordaremos;

5) La *actio adversus mensorem qui falsum modum dixerit*, es decir, contra el agrimensor que, designado árbitro de una con-

²³ D. 9, 3, 1 § 4, interpolado desde *culpa enim* hasta el fin.

²⁴ Cfr. el pasaje de la *Ethica ad Nicom.*, 1136 b, relativo a la sentencia injusta. Diversamente juzga, sobre el carácter de la acción, DE FRANCISCI, *Συνάλλαγμα*, II, ps. 129 y ss.

troversia de límites o perito de una venta o división, haya asignado dolosamente a una de las partes zonas que no le correspondían o dado medidas falsas. La limitación de la responsabilidad al dolo es aquí cierta aun para el derecho justiniano, no obstante la complicada manipulación de D. 11, 6, 1 § 1.

6) La *actio servi corrupto* corresponde al dueño de un esclavo a quien otro haya dado hospitalidad mientras estaba en fuga, o instigado o auxiliado en actos ilícitos, o persuadido a empresas peligrosas que hayan causado su muerte o lesión²⁵, contra el autor del hecho, por el doble de la disminución de valor del siervo, o del daño que el amo haya sufrido. Es dudosa la clasicidad de la acción útil que en D. 11, 3, 9 § 1, se da al usufructuario; y es ciertamente justiniana la *utilis actio servi corrupti* que la ley 14, § 1, da al padre por la corrupción del hijo.

7) La *actio sepulchri violati* se otorga contra aquel que "*sepulchrum alienum effregerit vel aperuerit eoque mortuum suum alienumve intulerit*". La acción, que como la precedente se funda sobre el dolo, se concede al titular del *ius sepulchri* (cfr. p. 190), pero si ella no procede, se hace lugar a una acción popular; la primera corresponde *in quantum aequum iudici videbitur*, la segunda por la multa fija de 100.000 sesteracios.

8) Una acción especial se concede contra el *publicanus*, es decir, el adjudicatario de los impuestos que usurpe, sin justo motivo, cosas de los contribuyentes. La acción es penal e *in duplum*, pero después del año es sustituida por una acción *in simplum*. La cláusula edictal respectiva (D. 39, 4, 1 pr.) fué ampliada por los justinianos, que le agregaron una acción especial de daño contra los publicanos, como así también una nota verdaderamente exuberante a la acción de hurto dada en otra parte del Edicto²⁶.

²⁵ Este último es un caso de *damnum non corpore datum*, para el cual JUSTINIANO da una *actio legis Aquiliae utilis* (D. 11, 3, 4, interp.).

²⁶ Cfr. ARANCIO-RUIZ, *Studii in onore di S. Perozzi*, 1925, ps. 229 y ss.

CAPÍTULO XVII

LAS MODALIDADES Y LOS LÍMITES DE LO ILÍCITO CIVIL*

Ilícito contractual y extracontractual. Remisión al capítulo precedente para la responsabilidad por delito: semejanzas y diferencias. — La responsabilidad objetiva en las obligaciones de dar. *Dolus*, *custodia*, *culpa*: el origen tardío de ésta y sus grados. *Casus fortuitus* y *periculum*. Pactos de aumento y de disminución de la responsabilidad. — La mora del deudor y sus efectos. La llamada mora del acreedor. — Los efectos de lo ilícito civil: valuación de la cosa debida y resarcimiento del daño.

Discurriendo en las páginas precedentes acerca de los actos ilícitos, hemos tenido oportunidad de precisar, para las figuras particulares de delito y cuasi delito, sus presupuestos objetivos y subjetivos, entendiendo por presupuestos objetivos los eventos externos, como la lesión personal o la remoción de la cosa ajena o el daño que se le causa, y por presupuesto subjetivo la correlación entre el evento mismo y el estado de ánimo del agente. Esta correlación puede ser, en abstracto, variadísima; pero para las hipótesis examinadas es posible ya la abstracción de ciertos criterios generales bajo los cuales pueden agruparse las diferentes especies. Hemos visto que los juristas atribuyen el máximo relieve, en la gran mayoría de los casos, al dolo (*dolus malus*), es decir, a la intención de alcanzar el evento para sanción del cual ha sido establecida la norma penal (hiero a alguien usando deli-

* Traducimos "torto", que es la expresión que emplea el autor, por "ilícito", en razón de no existir en nuestra lengua expresión que equivalga exactamente a la italiana mencionada. En otras partes de este mismo capítulo nos ha parecido preferible traducirla como "injusticia" o "injusto", aunque etimológicamente considerada la expresión correspondiente a lo que se hace sin razón [N. del T.].

beradamente con este fin y en su contra un arma apta para herir; doy refugio a alguien sabiéndolo esclavo fugitivo de la casa del amo); pero hemos visto también hipótesis (y, en particular, las del daño aquiliano, del *effusum et deiectum*, del *positum vel suspensum*) en las cuales se prescinde de esta intención, bastando el mero nexo causal entre la acción u omisión individual y el evento dañoso o peligroso que de ella deriva (la pelota con que jugaba ha ido a golpear el brazo de un barbero, y yo respondo frente al amo del esclavo a quien se cortó el cuello; mi siervo ha colocado un florero de manera que sobresaliese de la ventana, y, si el jarrón ha caído, respondo ante el transeúnte a quien ha lesionado en la cabeza). Hemos señalado también cómo el nombre de *culpa*, usado a veces por los clásicos para expresar este nexo, va tomando después, y especialmente en la época justiniana, un significado técnico de negligencia, de previsible no previsto, de impericia en el propio arte u oficio¹; y cómo otras veces la responsabilidad que el derecho clásico establecía sólo para la hipótesis del dolo, se extiende también a la imprudencia (ejemplo: *iudex qui litem suam fecit*).

Dolo, culpa, nexo causal, en las circunstancias en que son respectivamente acogidos por el ordenamiento jurídico como criterios de responsabilidad, confieren al evento objetivamente producido el carácter de *injusto**, y representan, en consecuencia, el elemento subjetivo.

Ahora bien: el concepto de lo injusto no encuentra aplicación solamente en los actos ilícitos; también en materia de contratos y de actos lícitos no contractuales se presentan los mismos problemas. Sólo que se presentan en un diverso momento: el acto ilícito es, él mismo, una injusticia, y la obligación *ex delicto* es su reparación; el contrato y los otros actos lícitos productores de obligación pueden, en cambio, dar lugar a injusticia, sólo en cuanto no se cumpla la obligación primaria.

*

* *

¹ Cfr., por ejemplo, D. 9, 2, 31 (intpl.): "*culpam autem esse, quod cum a diligente providere potuerit non esset provisum...*".

* Torto (N. del T.).

El problema subjetivo de la responsabilidad contractual² no se puede reducir, para el derecho romano, a los dos paradigmas del dolo y de la culpa, consistente el primero en la deliberada voluntad de no cumplir, la segunda en una negligencia, imprudencia o ineptitud para la tarea que se haya asumido, de la cual sea consecuencia el incumplimiento. Esta general bipartición es el común denominador a que la ciencia medieval ha reducido agudamente la casuística del derecho justiniano; pero en el derecho clásico, en cambio, los criterios son distintos de caso a caso.

Corresponde observar, ante todo, que el problema no se plantea siquiera cuando el objeto de la obligación consiste en la transmisión de una suma de dinero o de una cantidad de cosas fungibles, o de una cosa genéricamente indicada (por ejemplo, como consecuencia de una estipulación o de un legado de tales cosas). Ningún acontecimiento puede aquí ser tal que haga objetivamente imposible el pago, o que impida al acreedor proceder —según los diversos períodos históricos— contra la persona o contra los bienes del deudor; si tiene lugar una dificultad subjetiva para pagar, es principio esencial del intercambio a crédito, que ella sea soportada por el deudor.

Pero el problema comienza a plantearse para las obligaciones (procedentes de estipulación y de legado) de transmitir la propiedad de cosas individualmente determinadas; aquí puede producirse la imposibilidad objetiva para el cumplimiento, si la cosa prometida deja de existir o es puesta fuera del comercio. Esta imposibilidad material³ no representa por sí misma una causa de li-

² A él está dedicado mi volumen *Responsabilità contrattuale in dir. rom.* (2ª edic., Napoli, 1933), al cual remito para los detalles y la bibliografía. Agréguese LUZZATTO, *Caso fortuito e forza maggiore*, t. I, Milano, 1938; y por último el estudio póstumo de PFLUEGER, en "Rev. Fundac. Savigny", 65, 1947, ps. 121 y ss. Para los casos particulares, y en diverso sentido, WIEACKER, "Rev. Fundac. Savigny", 54, 1934, ps. 35 y ss. (sociedad); LAURIA, *Studi Riccobono*, 3, ps. 283 y ss., y VAZNY, *Atti cit.*, II, 527 y ss. (tutela); VocI, "Stud. e Docum.", 1, 1935, ps. 48 y ss. (legados); SACHERS, *ibid.*, 4, 1938, ps. 309 y ss. (neg. gestio), y "Rev. Fundac. Savigny", 59, 1939, ps. 432 y ss. (mandato); en general los manuales de [JÖRS-] KUNKEL, ps. 171 y ss., y de MONIER, 2, 4ª edic., ps. 226 y ss.

³ Imposibilidad sobreviniente que debe distinguirse netamente de la imposibilidad inicial, que se tiene cuando se deduce en obligación cosa que no existe en la naturaleza, o que ya se ha extinguido, o está fuera del comercio; en cuyos casos la obligación no nace.

beración del deudor; la liberación tiene lugar solamente cuando *per eum non stat quominus praestet*, es decir, cuando la pérdida de la cosa no depende de *hecho* suyo. Este concepto de "hecho del deudor" parecen haberlo entendido los romanos en sentido mucho más literal del que nosotros lo haríamos frente a una idéntica terminología legislativa; hecho del deudor es un acto positivo suyo, con exclusión de las omisiones (de manera que no puede, por ejemplo, imputarse al deudor el no haber curado, en ocasión de una enfermedad, al esclavo prometido: cfr. D. 45, § 1, 91 pr.)⁴; por el contrario, el punto de partida está en la indiferencia por el elemento intencional, hasta por la ignorancia en que eventualmente se halle el deudor sobre la existencia de la obligación, y sólo a través del análisis de especies particulares en las cuales este resultado aparecía particularmente inicuo, los juristas han llegado a admitir alguna excepción.

Pero el ámbito en el cual la indagación sobre los límites de la injusticia se hace más delicada es el de los innumerables contratos (consensuales y reales) y actos lícitos, en virtud de los cuales alguien está, como quiera que sea, obligado a elaborar, custodiar, restituir cosas ajenas o correspondientes en definitiva a otro (depósito, comodato, prenda, fiducia, locación, venta, etc.), o bien a administrar negocios ajenos (mandato, tutela, gestión, etc.). El problema, que ya entre los romanos fué objeto de delicadas investigaciones, figura entre aquellos sobre los cuales se ha detenido más intensamente en los últimos años la atención de los romanistas; aquí sólo pueden indicarse, a grandes trazos, las soluciones más generales.

Se halla entre los resultados que se pueden considerar más seguros, el de que la responsabilidad por dolo represente, en la mayoría de los casos, el punto de partida. Las fórmulas de los *bonae fidei iudicia*, que tienen en esta materia una aplicación preponderante, llevan el pensamiento de los juristas a lo que es la antítesis de la *fides bona*, el *dolus malus*; y si la limitación de la responsabilidad al dolo es inevitable para aquellos juicios de

⁴ *Cave a consequentiariis*: los romanos no han soñado jamás en negar la responsabilidad del deudor que deja morir de hambre al esclavo o al animal; la regla citada contempla la omisión de actividades que al pensamiento de los antiguos parecían excepcionales y dispendiosas.

buena fe cuya condena genera la infamia (cfr. p. 68), como las acciones de la tutela, del mandato y de la sociedad, no parece que la solución sea diferente para los que no son infamantes, como la *actio fiduciae*. El canon permanece fundamental también en los casos en que para ciertos aspectos especiales de la conducta del deudor entran en juego otros criterios; así, por ejemplo, la responsabilidad del comodatario se fundará también siempre sobre el dolo cuando se trate de apreciar su retardo en la restitución de la cosa o de haber hecho de ella un uso distinto al establecido. También las cláusulas del Edicto pretorio que prometen nuevas acciones y las fórmulas *in factum conceptae* relativas (como las del depósito y del comodato) ponen de relieve el presupuesto de que el demandado haya incurrido en dolo.

Pero desde antiguo se consideraba como un problema aparte el de la *conservación de la cosa* confiada a uno de los contratantes; en efecto, cuando la conciencia social exigía que la contraparte pudiese contar absolutamente con la restitución, o porque la ventaja del contrato fuese toda para el detentor o por otra razón, ella no se conformaba con considerarlo responsable sólo de la mala voluntad. GAYO (III, 205 y 206) indica dos de estas hipótesis: la entrega de vestidos al tintorero o al sastre, y el comodato. Parece natural la extensión a todo caso de *locatio operis faciendi*, y también es probable la extensión a la locación *rei utendae*, cuando tenga por objeto cosas muebles. Apoyándose en otro punto de partida, el de la particular asunción de responsabilidad que originariamente tenía lugar en el *receptum* (p. 373), el mismo criterio se ha aplicado también a los capitanes de buques, posaderos y dueños de establos. Y, en fin, también el vendedor, por lo menos cuando estuviese ya en retardo para la entrega de la cosa, quedaba sometido respecto de la conservación de ella, a la responsabilidad agravada. La naturaleza de ésta es expresada por GAYO y por otros juristas con las palabras *praestare custodiam*, y la aplicación práctica más notable está en que el deudor continúa siendo responsable si la cosa le ha sido robada estando en su poder, aunque él no hubiera de ninguna manera facilitado el hurto con su mala voluntad o negligencia. Algún jurista más severo consideraba que otro tanto ocurría si un tercero hubiese deteriorado la cosa, o si el esclavo entregado en comodato se hubiese fugado. Una consecuencia importante, ya señalada en la p. 413, es que la acción pe-

nal de hurto no compete al dueño de la cosa, sino a aquel que a título de custodia responde por ella⁵.

Por consiguiente, también en materia de contratos, como ya en materia de delitos, se nos presenta el doble sistema de la responsabilidad por dolo y de la responsabilidad objetiva. En efecto, GAYO, después de haber establecido el concepto del *praestare custodiam*, no lo compara con casos de responsabilidad por culpa, sino con la responsabilidad del depositario, que no va más allá del dolo: entre dolo y custodia parece que él pensara, *tertium non datur*. La deducción se impone cuando se observa que, en todas sus Instituciones, la palabra *culpa* aparece sólo dos veces (III, 202 y 211), y siempre a propósito de la *actio legis Aquiliae*, con el significado que oportunamente se señalara (p. 420).

Por otra parte, las investigaciones de derecho comparado parecen apoyar una hipótesis según la cual, en la concepción primitiva de lo ilícito civil, sería punto de partida fundamental el hurto, distinguiéndose entre los casos en los cuales el consignatario de una cosa responde contractualmente sólo si él mismo se ha apoderado de ella, y aquellos en que también responde si ha dejado que otro se la apropiara.

De todos modos, también para los contratos a los cuales se aplica la responsabilidad por custodia, el criterio del dolo continúa siendo, como se ha dicho, decisivo para todas las infracciones que no se resuelven en la pérdida material de la cosa; en consecuencia, no es correcto decir que en algunos contratos se responde de la custodia y en otros del dolo, sino que conviene agregar: por cuanto respecta a la conservación de la cosa que es su objeto.

La confirmación de la inexistencia de un canon intermedio de responsabilidad, como podría ser la culpa, se obtiene del análisis de los textos relativos a la *diligentia*. En inscripciones de la época republicana y del Principado, como también en los textos de la jurisprudencia que no han sido manipulados por los bizantinos, *diligentia* expresa, agregada o como ulterior determinación de la *fides bonae*, la obligación que incumbe a muchos contratantes, de ejercer una actividad positiva; pero, cuando se trata de apre-

⁵ Es necesario cuidarse, sin embargo, de la tentación de concluir, por el contrario, de la correspondencia de la acción de hurto, en la responsabilidad por custodia. Por ejemplo, el acreedor prendario tiene la acción de hurto, pero no parece que responda de la custodia (ver mi ob. cit., ps. 188 y ss.; de otra manera LUZZATTO, *op. cit.*, ps. 233 y ss.).

ciar el estado del sujeto que ha omitido tal actividad, se exige siempre que él la haya omitido por mala voluntad, por dolo.

Es indudable que la idea de la *culpa* como base de la responsabilidad es tardía. A ella se llega por el mismo doble procedimiento que hemos observado en las figuras típicas del cuasi delito justiniano: restringiendo a los límites de lo previsible no previsto la responsabilidad objetiva del *conductor operis facienti*, del comodatario, del capitán; extendiendo hasta la negligencia o imprudencia la originaria responsabilidad por dolo del mandatario, del tutor, del socio, del fiduciario. El caso más antiguo de responsabilidad por culpa, en materia afín a la contractual, parece ser el del marido en la restitución de la dote (*actio rei uxoriae*; cfr. cap. XXI, § 4); el desarrollo posterior es, en buena parte, debido a las escuelas posclásicas, y los compiladores de JUSTINIANO le han opuesto diques en lugar de haberlo proseguido. Indudablemente, ninguna palabra está tantas veces interpolada en el Digesto como *culpa*⁶; pero aun donde es genuina y resulta posible la referencia a lo ilícito contractual, queda abierta y gravísima la cuestión en torno al significado. En efecto, si en el uso literario, como MITTEIS lo ha observado, *culpa* expresa siempre un simple nexa causal, si al mismo resultado debe llegarse para el uso de la palabra en materia de daño aquiliano, es fácil admitir que no debió ser diferente su uso eventual en materia de responsabilidad derivada del contrato. También en la materia de los contratos, lo previsible no previsto pertenece a los juristas posclásicos.

Los justinianos —decíamos—, en aquellas interpolaciones que indudablemente han sido efectuadas por ellos, han obstaculizado, más que favorecido, la unificación de la responsabilidad bajo el criterio de la *culpa*. Deseosos de conservar en esta parte buen número de soluciones clásicas, han continuado siendo particularmente severos en los casos en que en un tiempo se respondía de la custodia, sólo que ésta ha sido sustituida por una *exactissima diligentia custodiendae rei* (que es siempre, en el sistema de la compilación, algo más que la común *culpa*); por el contrario, en ciertas hipótesis en que la responsabilidad clásica estaba limitada al dolo y las

⁶ Se trata, bien entendido, de interpolaciones prejustinianas, en las cuales ni siquiera los compiladores, en caso de que lo hubieran querido, habrían podido reparar, dado que los textos habían llegado a ellos en este estado.

escuelas posclásicas la habían extendido a la culpa, por ejemplo en materia de sociedad, han dejado fuera una *diligentia quam in suis rebus socius adhibet* (que es algo menos que la piedra de toque habitual).

En el sistema del *Corpus iuris*, donde las diversas tendencias se aproximan sin converger exactamente, encontramos dos clasificaciones de la culpa o de la diligencia, una posclásica y la otra justinianeas, poco menos que coincidentes en la práctica, aunque inspiradas en diversos conceptos:

1º) *Culpa levis* y *culpa lata*. De la mayor o menor gravedad de la culpa, cuya valoración es atribuida al juez, derivan consecuencias de importancia; propia y verdadera culpa es, en los efectos prácticos, solamente la primera, mientras vale la regla de que *lata culpa dolo aequiparatur*, o directamente *dolus est*; caso principal de aplicación es el depósito⁷.

2º) *Diligentia diligentis patris familias* y *diligentia quam suis* (en la terminología de los romanistas, *culpa in abstracto* y *culpa in concreto*). La primera se valora según una piedra de toque ideal; es decir, la diligencia que un buen padre de familia observa en las cosas propias; la segunda se estima con relación a la diligencia, eventualmente inferior, que el obligado observa para sus cosas. La *diligentia quam suis* se halla aplicada especialmente a las obligaciones del tutor y del socio, y a la obligación del marido de restituir la dote.

Más allá de toda responsabilidad está el *casus fortuitus*, o *vis maior*, pérdida de la cosa por causa natural o por irresistible violencia de terceros; rige aquí el principio de la liberación del deudor de todo vínculo. Los textos insisten en poner de relieve que vale solamente para aquellos acontecimientos que ninguna prudencia humana podría prever y evitar, como el terremoto o el naufragio (las llamadas *θεοῦ βία*, violencias divinas) y para los hechos humanos cumplidos con gran despliegue de fuerza, como un ataque de piratas o de bandidos. En los supuestos en que se respondía por la custodia, estos casos espectaculares eran los únicos de los cuales el deudor no era responsable; precisamente por su rareza, ocurría, a veces, que se los olvidara. diciéndose que por

⁷ Haber demostrado el origen espúreo de estas máximas es mérito de nuestro extinto DE MEXIO, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 17, 1905, ps. 1 y ss.; 18, 1906, ps. 260 y ss. Sobre la *culpa levissima*, cfr. p. 420.

ejemplo el comodatario asumía *omne periculum*; pero está en error quien cree que en este o aquel caso la responsabilidad no quedase excluida ni siquiera por la fuerza mayor.

Los criterios de responsabilidad que el derecho objetivo determina para cada contrato constituyen, por lo común, un elemento natural (p. 94), tal que pueda ser modificado con pactos especiales entre las partes; la responsabilidad puede ser agravada o atenuada por tales pactos, con la única reserva de la ineficacia del *pactum ne dolus praestetur*; se admite, por lo demás, el pacto de no ejercer la acción (por ejemplo, *ne depositi agatur*), que puede conducir al mismo resultado práctico⁸.

*
* *

A menudo, y en particular en las obligaciones que tienen por objeto la dación o entrega de una cosa o suma, la injusticia toma figura de *mora*, es decir, de retardo en el cumplimiento de la obligación. Para que haya *mora* es necesario que la obligación sea *pura*, es decir, no condicional, que sea exigible (es decir, no sujeta a un término todavía no vencido)⁹, y que el retardo sea imputable al deudor, en los límites que entrañan las diversas causas de obligación. Sobre la determinación del tiempo en el cual se puede hablar de *mora*, parece que los clásicos procedían diferentemente según las circunstancias; si la obligación era a término o bajo condición, el cumplimiento del término o la verificación de la condición ponen en *mora* al deudor; otras veces (por ejemplo, un caso de depósito) la *mora* se produce cuando el acreedor ha requerido inútilmente el cumplimiento. El derecho justiniano sienta, sin más, el principio de que la *mora* se produce a partir de la *interpellatio*, exceptuando varios casos particulares y entre éstos —parece— las obligaciones a término; la regulación especial de

⁸ Diversas explicaciones de la antinomia en DI MARZO, *Studi in onore di V. Lilla*, p. 168; ALBERTARIO, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 25, 1913, ps. 33 y ss. (= *Studi di dir. rom.*, IV, ps. 253 y ss.); mejor SEGRÈ, *Studi in onore di C. Fadda*, VI, p. 350, y ROTONDI, *Scritti giuridici*, II, ps. 120 y ss.

⁹ Los dos presupuestos son expresados por los romanos contraponiendo un *dies cedens* a un *dies veniens*. Cfr., por ejemplo, D. 50, 16, 213 pr. (Ulpiano): "Cedere diem significat incipere debere pecuniam; venire diem significat eum diem venisse, quo pecunia peti possit".

estas últimas era expresada por los juristas medievales con la máxima *dies interpellat pro homine*¹⁰.

Los efectos de la mora son de dos clases. En primer lugar, en las obligaciones que tienen por objeto la dación o la restitución de una cosa, la mora produce la llamada *perpetuatio obligationis*; esto quiere decir que si *post moram* la cosa es destruída, así sea por caso fortuito, el deudor soporta las consecuencias. Este principio, que en el derecho clásico parece no haber sufrido limitaciones, es entendido por los justinianeos en sentido más estricto, es decir, en el de que el deudor responda por esa pérdida que ha dependido —aunque sea fuera de toda previsibilidad— del hecho de haber permanecido la cosa en su poder (por ejemplo, si ha sido destruída por un terremoto que no ha causado igualmente estragos en la casa del acreedor); puede, en consecuencia, liberarse demostrando que en la hipótesis de cumplimiento a su debido tiempo, la cosa habría igualmente perecido. Un efecto particular tiene luego la mora en las obligaciones que dan lugar a juicios de buena fe; sobre la base del "*quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona*", los juristas imponen al deudor moroso la obligación del pago de los intereses (*usurae quae officio iudicis praestantur*, en oposición a las *usurae quae sunt in obligatione*).

Al lado de la mora del deudor se habla —inexactamente, porque la afinidad es más aparente que sustancial— de mora del acreedor o *mora accipiendi*. Esta tiene lugar cuando el deudor ofrece el pago íntegro de la deuda y el acreedor no lo acepta. El efecto principal recae también aquí sobre los límites de la responsabilidad del deudor; por lo menos en derecho clásico, desde el momento de la oferta no aceptada, naturalmente siempre que el acreedor no tuviese razón para rehusarla, el deudor responde de la pérdida de la cosa solamente en caso de dolo¹¹. Desde el mismo momento cesa, por lo menos en los casos en que la oferta se ha hecho con particulares solemnidades (*in publico* o *in aede sacra*), la obligación eventual de los intereses; por el contrario, el deudor puede rehusar el pago que sucesivamente se le requiera si no se le reembolsan los gastos que ha soportado a causa del retardo. En el

¹⁰ Cfr. SIBER, *Interpellatio und mora*, en "Rev. Fundac. Savigny", 29, 1908, ps. 47 y ss.

¹¹ En el derecho justiniano, parece manifestarse alguna tendencia a extender también aquí la responsabilidad hasta la culpa: cfr. D. 46, 3, 72 pr.

derecho justinianeo, la oferta solemne y el respectivo depósito de la suma parecen producir, sin más, la extinción de la obligación¹².

Tanto la mora del deudor como la del acreedor pueden purgarse, de modo que sus efectos no continúen produciéndose en lo futuro; para la del deudor, la purga se realiza cuando se hace al acreedor la oferta del pago íntegro sin que él pueda invocar una justa causa de rechazo de la oferta; para la del acreedor, cuando él mismo se ofrece a aceptar el pago precedentemente rehusado y a resarcir el daño y los gastos soportados por el deudor.

*
* *

Cuando el cumplimiento de una obligación se hace imposible por un hecho del cual, según los criterios ya examinados, el deudor debe responder, la acción que la protegía permanece intacta. Es ésta una consecuencia de la estructura de la fórmula romana, la cual, mientras está construida (*intentio*) sobre la base de la obligación de cierto comportamiento, remata siempre en una condena pecuniaria. Cuando el cumplimiento es posible, el deudor puede con él evitar la condena; si no lo es, la condena se hace inevitable.

No se describiría exactamente el contenido de la condena romana si se tomase prestado del art. 1218 del Código italiano el nombre y el concepto del resarcimiento del daño; el derecho romano tiene condenas de contenido diverso según la estructura de la fórmula¹³. En la *condictio certae rei*, por ejemplo, y en las análogas acciones *ex stipulatu* y *ex testamento*, la condena es al *quantum ea res est*, es decir, originariamente, al puro y simple valor de la cosa que debía ser dada y no lo fué; sin embargo, si se ha llegado en algunos casos particulares a extender esta estimación hasta tener alguna cuenta del más vasto perjuicio eventualmente sufrido por el acreedor, esto ha sucedido siempre dentro de límites restringidos. Pero en las mismas fórmulas, o en las de otras acciones, puede acontecer que la cláusula *quantum ea res est* se refiera,

¹² Sobre esto, y sobre cuanto sigue, cfr. GUARNERI-CITATI, *Contributi alla dottrina della mora*, en "Annali Semin. Giur. Palermo", 11, 1923, ps. 161 y ss.

¹³ Sobre el tema cfr. especialmente KASER, *Quantum ea res est*, Monaco, 1934; y VOCI, *Risarcimento del danno e processo formulare*, Milano, 1938.

antes que a una cosa en sentido propio (corporal), al daño que se ha causado al actor o a la ventaja de que se lo ha privado; en estos casos, estimar la *res* significa valorar el perjuicio que el actor ha sufrido¹⁴.

Mucho más ampliamente dominaba el mismo concepto del interés del acreedor (*id quod interest*) en los *bonae fidei iudicia*, y en los otros (por ejemplo, la *actio ex stipulatu incerti*) en los cuales la condena se proporcionaba al "*quidquid... dare facere oportet*". De cualquier manera, también el concepto del interés del acreedor es diversamente entendido en las distintas hipótesis. Así, del análisis de los textos, los modernos han extraído la distinción entre dos órdenes de ideas: la del interés negativo (restitución del acreedor en las condiciones en que se habría encontrado si no hubiese celebrado el contrato) y la del interés positivo (ventaja económica que el acreedor habría podido obtener del contrato exactamente cumplido). La jurisprudencia oscila entre ambos; pero parece que ya entre los clásicos prevaleciera la consideración del interés positivo. Más inciertos son los límites dentro de los cuales la jurisprudencia ha comprendido en el *id quod interest*, al lado

¹⁴ Un caso del género es el comprendido bajo la rúbrica edictal *de eo quod certo loco dari oportet*, a propósito de las estipulaciones y de los legados que tienen por objeto la dación de una cosa o suma cierta en un lugar determinado. Parece (cfr. GAYO, IV, 53 c.) que el problema hubiera sido tomado por primera vez en consideración, por la razón procesal de que aquel que en estas circunstancias demandase pura y simplemente la entrega, cometería una *plus petitio* (p. 137) y vería rechazada su pretensión. Para evitarlo, tanto en la acción *certae creditae pecuniae* y en la *condictio certae rei* como en las fórmulas correspondientes *ex stipulatu* y *ex testamento*, se modificó la *intentio*, introduciendo en ella la mención del *locus solutionis*. Pero más tarde la jurisprudencia observó que, siendo por lo común la designación del lugar hecha en interés del acreedor, éste viene a perder alguna parte del valor que se le debe si la entrega se hace en el domicilio del deudor o en cualquier otro sitio impuesto por las normas sobre la competencia; y admitió, por ello, la posibilidad de una condena a una suma superior a la adeudada o al valor de la cosa debida. Es muy discutido en qué forma esta facultad de aumento de la condena estuviera expresada en la fórmula de la *actio certae creditae pecuniae*, cuya *condemnatio* lleva, por lo común, como sabemos (p. 140), la misma suma que la *intentio*; para la *condictio certae rei*, es indudable que a ello se llegó a través del *quanti ea res est*. La institución es también en otros puntos objeto de discusión, sobre todo porque los textos darían fe, asimismo, de la posibilidad de disminuir la condena en consideración a un eventual *interesse loci* del deudor (cfr. sobre el tema mis *Studii formulari*, I: *De eo q. c. l. d. o.*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 25, 1913, ps. 130 y ss.).

del daño emergente, también el lucro cesante; aquí, sin embargo, parece que hayan sido los justinianeos quienes pusieron la distinción en primer plano¹⁵. De todos modos, los juristas se limitan, en la estimación del daño, a las consecuencias perjudiciales que directa y normalmente derivan del incumplimiento, y no llegan a las indirectas o peculiares del acreedor particular¹⁶. El concepto justiniano de que el daño no puede superar el doble valor de la cosa, se inspira en un criterio que en algún caso había sido seguido por los clásicos (cfr. la *stipulatio duplae* para la evicción, p. 382), pero como principio general es inaceptable.

FRANJA
MORADA

¹⁵ Cfr. GUARNERI-CITATI, *Miscellanea esegetica* (extr. "Annali Fac. Giur. Perugia", 37, 1924), ps. 68 y ss.

¹⁶ Contra la opinión opuesta de F. HAYMANN (*Studi Bonfante*, 2, ps. 443 y ss.), cfr. [JÖERS-] KUNKEL, *Römisches Recht*, p. 171, n° 8.

FRANJA MORADA

CAPÍTULO XVIII

EXTINCIÓN, TRASMISIÓN, GARANTÍAS DE LAS OBLIGACIONES

§ 1. LOS MODOS DE EXTINCIÓN

Extinción *ipso iure* y *ope exceptionis*. El desarrollo del concepto de *solutio* y las instituciones del derecho clásico y justiniano: 1) el pago; 2) la *solutio per aes et libram*; 3) la *acceptilatio* verbal y literal; 4) el *contrarius consensus*. Otros modos de extinción *ipso iure*; 5) novación; 6) *concursus causarum*; 7) confusión. Modos eventuales de extinción de las obligaciones: 8) muerte y *capitis diminutio*. Los modos de extinción *ope exceptionis*: 9) la compensación y su casuística en el derecho clásico y justiniano; 10) el *pactum de non petendo* y la transacción; 11) la *praescriptio longi temporis*.

La expresión "modos de extinción de las obligaciones" puede tener un doble significado. En el sentido más estricto, extinguen la obligación solamente aquellos hechos jurídicos que destruyen la relación de deuda y de crédito, de manera que el juez investido de la controversia, deba declarar inexistente el *dare* o *facere oportere* afirmado por el acreedor demandante; son éstos los modos de extinción *ipso iure*, propios del derecho civil. En un sentido más amplio, fundado sobre la identidad del resultado práctico, se acostumbra a comprender entre los modos de extinción de las obligaciones, también a algunos hechos que por una ley limitativa del *ius civile*, o por derecho pretorio, ponen al deudor en condición de poder rechazar la acción del acreedor a través de la inserción de una *exceptio* en la fórmula; aquí el *dare* o *facere oportere* subsiste, pero el juez no debe limitarse a verificar sus presupuestos, sino que debe, en un segundo momento, establecer si es fundada la reserva opuesta por el deudor, y en la afirmativa debe

absolverlo a pesar de que él quede civilmente *obligatus* (cfr. ps. 148 y ss.). De aquí el nombre de modos de extinción *ope exceptionis*.

*
* *
*

En los orígenes, la extinción *ipso iure* coincidía sin residuos con la *solutio*. En efecto, se ha dicho ya que *solvere* equivale a "desligar" (p. 316) y expresaba antiguamente el acto con el cual el deudor se desligaba del vínculo obligatorio. En la forma más arcaica, que es la *solutio per aes et libram*, el deudor pronunciaba precisamente las palabras: *ego me a te solvo liberoque*. En general, era necesario un acto igual y contrario a aquel con el cual la obligación había nacido; así, a los negocios obligatorios *per aes et libram* (*nexum*, legado *per damnationem*) correspondía la llamada *solutio p. aes et l.*, a la *expensi latio* (p. 365) la *accepti latio* literal, a la *stipulatio* la *accepti latio* verbal¹.

Pero más tarde se admitió que en todo caso, quien cumpliera su prestación, aun sin una solemne declaración liberatoria, se desligara del vínculo, y *solvere* tomó el sentido de nuestro "pagar", teniendo por objeto no más al deudor sino a la prestación misma, y aplicándose con preferencia cuando ésta consistía en la dación de una cosa, con mayor razón de una suma de dinero. En el nuevo sentido, *solutio* es el pago, en antítesis con todos los otros hechos por los cuales se extinguen las obligaciones (*tolluntur*). Los actos solemnes que inicialmente eran necesarios para extinguir las obligaciones continuaban en uso, pero quedan como *imaginariae solutiones* para declarar extinguidas obligaciones no efectivamente cumplidas (remisión). De esta última serie de actos se conserva en el derecho justiniano sólo la *accepti latio* verbal; en cuanto a la terminología, hay una especie de retorno a lo antiguo, en cuanto el verbo *solvere* vuelve a emplearse con frecuencia en el sentido

¹ Esta regla de la correspondencia entre el acto que da nacimiento a la obligación y el que la extingue es hoy en muchas partes condenada como invención posclásica; pero en verdad, mientras en el derecho de la nueva época no era exactamente aplicada, una glosa griega a los fragmentos egipcios de GAYO hace muy probable la genuinidad del pasaje de PAULO en D. 50, 17, 153 y, por consiguiente la de los pasajes paralelos.

amplísimo de extinción de la obligación, de cualquier manera que ella ocurra².

1. *Solutio* es, pues, en el significado clásico, el pago, el cumplimiento de la obligación, la observancia del comportamiento a que el deudor estaba obligado frente al acreedor³. No siempre es necesario que tal comportamiento lo observe el deudor mismo (antes bien, ello sólo se exige en las obligaciones *in faciendo*, fundadas sobre aptitudes especiales); para la mayor parte de las obligaciones (especialmente para las *in dando*) el pago hecho por cualquier tercero tiene eficacia liberatoria, y depende de las diversas relaciones entre deudor y pagador establecer si y cuál acción de regreso tiene éste contra aquél. El pago puede efectuarse al acreedor, a su procurador o mandatario; pero la estipulación admite también dos figuras particulares de indicación de un tercero para el pago: la *adiectio solutionis causa* y la *adstipulatio*. Se tiene *adiectio s. c.* cuando el acreedor estipula *mihi aut Titio dari spondes?*: *Titius* no se hace acreedor, pero el deudor puede liberarse pagándole, y las relaciones entre acreedor y *adiectus* se regulan, por lo menos normalmente, con la *a. mandati*. En cambio, se da la *adstipulatio* cuando a la estipulación de la que nace la obligación se hace seguir inmediatamente una segunda, hecha por persona de confianza del acreedor y que tiene el mismo objeto que la primera; no sabemos cuál era su forma, pero debía resultar indudable su carácter accesorio; de cualquier modo, el *adstipulator* es formalmente un segundo acreedor y puede, en consecuencia, obrar en juicio contra el deudor. También él es, sin embargo, por lo común, un mandatario del estipulante principal, y las relaciones entre ellos se regulan mediante la *a. mandati*⁴. Si no ha habido ni *adiectio* ni *adstipulatio*, el pago hecho a un tercero no es válido; pero el deudor puede oponer la *exceptio doli si* a través del tercero el objeto ha llegado al acreedor.

² Cfr., sobre este punto, CUGIA, *Confusione perinde extinguitur obligatio ac solutione*, Napoli, 1927.

³ Sobre el tema cfr. la amplia exposición de SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione*, 2ª ed., Napoli, 1935, ps. 33 y ss.

⁴ La institución no estaba muy difundida ni siquiera en la época clásica; entre las explicaciones que se dan acerca de la importancia que el derecho antiguo le reconocía, la mejor es la que la considera como un modo de evitar los efectos de una originaria intrasmisibilidad activa de las obligaciones (cfr. p. 335, nota 3).

Cuando por su contenido y sus modalidades la obligación es tal que pueda cumplirse en una sola vez, el acreedor no está obligado a aceptar un pago parcial; de la misma manera, si la obligación implica varias prestaciones consecutivas, el deudor no puede ulteriormente fraccionarlas sin el consentimiento del acreedor.

Cuando entre dos personas hay varias deudas de dinero, el deudor puede imputar a la que crea más conveniente el pago de una suma. Si no se ha hecho la imputación, se aplican diversas reglas⁵: se entiende extinguida antes la deuda vencida que la no vencida, antes la más gravosa que la menos gravosa (teniendo en cuenta el monto de la eventual condena, la infamia que puede acompañarla, la existencia de una prenda, etc.); antes la deuda por intereses que la del capital; en este último caso, debe observarse que está excepcionalmente prohibido al deudor disponer de otra manera (como en el art. 1194, Cód. Civ. it.).

El acreedor no puede ser constreñido a aceptar cosa distinta de la que se le debe; solamente en el acto del proceso la condena pecuniaria hace que el acreedor deba soportar que el objeto de la obligación sea sustituido por una suma de dinero. Si el acreedor acepta que se le pague *aliud pro alio*, se tiene la *datio in solutum*. Ajustándose a un concepto demasiado riguroso de la *solutio*, los proculeranos entendían que en este caso la obligación quedaba extinguida solamente *ope exceptionis* (en el sentido de que el acreedor, habiéndose conformado con otro objeto, incurriría en dolo si pretendiese otra vez el objeto que estaba *in obligatione*); pero, según los sabinianos, cuya doctrina prevaleció, la extinción se verificaba *ipso iure*. Probablemente es justiniana la doctrina según la cual la *datio in solutum* "*vicem venditionis obtinet*" (C. 8, 44, 4), con todas sus consecuencias (RABEL, DE FRANCISCI, SOLAZZI). Para JUSTINIANO existe también un caso de *datio in solutum* necesaria: cuando el deudor no puede procurarse dinero y posea inmuebles, debe ofrecer a sus acreedores que satisfagan los créditos sobre éstos, valorándolos según justa estimación.

2. De los actos formales que hemos visto estar comprendidos en el concepto de *solutio*, el más antiguo es la *solutio per aes et libram*, modo de extinción sea del *nexum*, sea de la obligación del heredero en virtud de legado *per damnationem*, sea —según pa-

⁵ En alguna parte justinianas: cfr. SIBER, "Rev. Fundac. Savigny", 45, 1925, ps. 174 y ss.; SOLAZZI, op. cit., ps. 132 y ss.

rece— de todas las otras deudas procedentes de una *iudicatio* o *damnatio*. El formulario nos lo indica GAYO (III, 174) y es, en la parte mímica, el mismo de la *mancipatio* (ps. 222 y ss.); pero la declaración es la siguiente⁶: “QUOD EGO TIBI TOT MILIBUS SESTERTIORUM IUDICIO CONDEMNATUS SUM (o bien: QUOD EGO TIBI EX TESTAMENTO L. TITII TOT MILIBUS SESTERTIORUM DAMNATUS SUM, o análogamente), EO NOMINE ME A TE SOLVO LIBEROQUE HOC AERE AENEAEQUE LIBRA”⁷. Como se ha señalado, antiguamente el acto solemnizaba un verdadero pago, pero en la época clásica sólo se lo usaba con fines de remisión de la deuda; en la época justiniana ha desaparecido como todos los *gesta per aes et libram*.

3. La *acceptilatio* puede ser literal o verbal, en armonía con la obligación a cuya extinción está destinada; el enorme predominio de la *stipulatio* hace que de la misma manera prevalezca la *acceptilatio* verbal. De las formas empleadas para la *acceptilatio* literal nada sabemos; la verbal se cumple, como la *stipulatio*, mediante pregunta y respuesta, salvo que esta vez es el deudor quien pregunta: *centum sestertios quos tibi spopondi acceptos habes?*, y el acreedor quien responde: *habéo*. Usada ampliamente en la época clásica y en la justiniana, como modo de remisión de la deuda (el uso primitivo como pago formal se conserva solamente en las cláusulas de estilo de los recibos o cartas de pago), pareció oportuno a la jurisprudencia extenderla también fuera del ya amplísimo círculo de obligaciones contraídas mediante estipulación; a este fin se hacía preceder la *acceptilatio* de una estipulación novatoria a la cual se volcaba el contenido de la obligación causal preexistente. Análogamente, se pudo trasfundir en una sola estipulación el conjunto de todas las deudas de una persona hacia otra (*Aquilianae stipulatio*) y hacer seguir la *acceptilatio*. También este acto sufrió más tarde las influencias provinciales a las cuales la estipulación debió su degeneración (*supra*, ps. 368 y ss.); en

⁶ La refiero según la versión de P. S. I., XI, 1182, distinta y probablemente más correcta que la del manuscrito veronés.

⁷ GAYO agrega: “HANC TIBI LIBRAM PRIMA POSTREMAMQUE EXPENDO SECUNDUM LEGEM PUBLICAM”. Esta cláusula se remonta hasta el tiempo en que la *mancipatio* y todos los actos elaborados sobre ella, importaban la pesada efectiva; entonces, en aquellos casos en que la suma era notable, se hacían necesarias varias pesadas, y el *mancipio accipiens* las contaba: *hanc tibi libram primam, hanc tibi libram alteram*, etc., *expendo*. Cuando la pesada se hizo imaginaria, fué siempre una sola: *prima postremaque*.

efecto, mientras la doctrina clásica de la *acceptilatio* está todavía expuesta en las Instituciones y en el Digesto, los papiros de la época bizantina prueban que sobre todo el nombre de la *stipulatio Aquiliana* era abusivamente empleado en documentos de transacción, sin que se cumpliese ninguna solemnidad verbal.

4. Del mismo modo, las obligaciones nacidas de contrato consensual se extinguen, *re adhuc integra* (es decir, antes de que una de las dos partes haya cumplido la prestación), con el *consensus contrarius* o disenso; la norma parece establecida en las fuentes genuinas sólo para la compraventa, pero no se ve por qué no deba aplicarse también a la locación; para la sociedad y para el mandato es absorbida por la licitud del receso unilateral (cfr. ps. 390 y 393).

5. A diverso orden de ideas responde la novación (*novatio*), que es definida como "prioris debiti in aliam obligationem [vel civilem vel naturalem itp.] transfusio atque translatio" (D. 46, 2, 1 pr.); es, en suma, la sustitución de una vieja obligación por una nueva que tiene el mismo contenido económico. El elemento esencial es un *aliquid novi* en la segunda obligación respecto de la primera; y precisamente se podría repetir en general cuanto escribe GAYO para aquella forma de novación que es el *nomen transscripticium* (p. 365)⁸, distinguiendo entre una novación *a re in personam* y una novación *a persona in personam*. En efecto, se tiene una novación cuando una deuda, cualquiera que sea su causa, se trasfunde en uno de los dos contratos formales típicos (*expensilatio* o *stipulatio*; como también si de una precedente deuda derivada de estipulación se cambia el término o se elimina la condición, etc.), o cuando con las mismas formas la deuda de una persona es asumida por otra (*expromissio*), o cuando al acreedor originario lo reemplaza uno nuevo (*delegatio*).

En la forma que conocemos mejor (o menos mal), es decir, en la estipulación novatoria, es necesario que esté exactamente descrita la obligación precedente: por ejemplo, en las diversas hipótesis, *centum sestertios quos mutuos tibi dedi dari spondes?*

⁸ Se suele negar, en verdad, que el *nomen transscripticium* represente una novación; pero la razón que al efecto se invoca, o sea que en materia de novación (III, 176 y ss.) GAYO recuerda sólo la realizada por estipulación, no prueba nada, si se piensa en la preponderancia de la forma verbal. De otra manera, fundándose en GAYO, III, 169 y ss., habría que negar también la existencia de la *acceptilatio* literal.

centum sestertios quos L. Titius mihi debet dari spondes? centum sestertios quos C. Seius a te stipulatus est mihi dari spondes? Es cierto que en estas fórmulas se expresa, por regla, la voluntad de las partes de novar la obligación en los diferentes sentidos analizados; pero, una vez pronunciada la fórmula, ya no es de la voluntad de novar sino de la fórmula misma que deriva el efecto jurídico. En el derecho justiniano, en cambio, la ya observada decadencia de los *verba stipulationis* y su traducción en cláusulas documentales "*quibuscumque verbis... compositae*" (cfr. ps. 369 y ss.) hace que el antiguo criterio formal desaparezca, sustituido por la indagación de la voluntad de las partes; de aquí la doctrina del *animus novandi*, establecida con singular relieve en la compilación, y consistente en requerir, caso por caso, que quien tenga interés demuestre la voluntad de novar, sin lo cual la nueva estipulación tendría el único efecto de aumentar los medios judiciales a disposición del acreedor.

Para que haya novación es necesario que sea válida la obligación preexistente; en cuanto al contrato novatorio, debe ser concluido, con las debidas formas, entre personas genéricamente capaces de contraerlo, sin cuyo requisito la novación no se produce y la antigua deuda subsiste; pero si la nueva promesa es inválida por cualquier otra causa, por ejemplo porque un pupilo ha prometido *sine tutoris auctoritate* o una mujer ha tomado a su cargo la responsabilidad por la deuda de otro (*intercessio*, p. 452, n. 18), la obligación antigua queda igualmente extinguida, aunque la nueva no llegue a nacer o sea paralizada por una excepción. La novación bajo condición deja intacta la obligación precedente mientras la condición no se cumpla; sin embargo, si durante la pendencia el acreedor pretendiese la ejecución de la *prior obligatio*, se le opondría una *exceptio pacti*⁹.

La extinción que produce la novación lleva consigo la pérdida de las garantías reales y personales correspondientes a la obligación precedente, y la inoponibilidad de las excepciones que el deudor habría podido hacer valer; solamente cuando la forma usada era tal que volcara en la estipulación novatoria no ya el objeto de la obligación precedente (ejemplo: *centum sestertios*

⁹ Cfr. KOSCHAKER, *Bedingte Novation und pactum* [Novación condicional y pactum], en los *Festschrift für G. Hanausek* [Estudios en honor de G. Hanausek], 1925, ps. 118 y ss.

quos a L. Titio stipulatus sum) sino la vieja deuda como tal (ejemplo: *quod mihi L. Titius debet*), parece que las excepciones permanecieron intactas¹⁰.

Hay una notable afinidad entre el caso de la novación y el de la *litis contestatio*, descrito en las ps. 371 y ss.; pero corresponde recordar que no obstante la transformación de la obligación originaria (*dare oportere*) en el llamado *condemnari oportere*, es justificada orientación de la jurisprudencia la de evitar que el comienzo de la controversia altere, desde el punto de vista económico, la posición de las partes; hemos visto ya que conserva su vida la prenda (p. 295); dígase lo mismo de los *privilegia exigendi* y de la obligación de pagar los intereses.

6. Se tiene el *concurso causarum* cuando la cosa (o prestación) individualizada que se nos debe la obtenemos, antes de que aquella obligación se cumpla, por un título diverso. Parece que la más antigua jurisprudencia considerase extinguida en todo caso la obligación, por no poderse concebir que ésta tuviese por objeto una cosa del acreedor. Más tarde (y ciertamente es así en la época justiniana) se establece la distinción según que la cosa debida la adquiriera el acreedor a título oneroso (por ejemplo, venta o permuta) o a título lucrativo (legado o donación); cuando por lo menos una de las dos causas es onerosa, la obligación subsiste, traduciéndose en el derecho de pretender del deudor el valor de la cosa; si ambas son lucrativas, la obligación se extingue. Se discute en qué medida este último régimen se remonta hasta el derecho clásico, por lo menos desde Juliano en adelante¹¹.

¹⁰ Sobre todo esto cfr. RABEL, *Lineamenti*, p. 487.

¹¹ Los diversos puntos de vista son los siguientes: 1) los clásicos han permanecido firmes en la doctrina más antigua, mientras la que restringe a las causas lucrativas el efecto extintivo del *concurso causarum* es justiniana (DI MARZO, *Appunti sulla dottrina della causa lucrativa*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 15, 1903, ps. 91 y ss.; 17, 1905, ps. 103 y ss.); 2) la antigua doctrina, contra la cual ya oponían diversas objeciones los juristas proculeyanos, fué corregida por Juliano, admitiendo que el destinatario de un acto de liberalidad, en particular de un legado *per damnationem*, conservase contra el heredero la acción *ex testamento* cuando hubiese adquirido la propiedad de la cosa a título oneroso, y que análogamente, el comprador de una cosa conservase la *actio empti* si la cosa hubiese llegado a ser suya a título de legado; la obligación se extinguía no sólo si ambas causas eran lucrativas, sino también si eran las dos onerosas (SCHULZ, *Die Lehre vom conc. caus.*, etc. [La doctrina del conc. caus. en el derecho clásico y justiniano], en "Rev. Fundac. Savigny", 38,

7. Las obligaciones se extinguen, además, por *confusión*, es decir, cuando las cualidades de acreedor y de deudor vienen a coincidir en la misma persona, fenómeno análogo al ya examinado en materia de servidumbres (p. 275).

8. Se extinguen, en fin, en ciertos casos determinados, por *muerte* o por *capitis deminutio* de uno o del otro sujeto; los casos principales los hemos visto al estudiar la sociedad (p. 389), el mandato (p. 393), las obligaciones procedentes de delito (p. 409); para las del *sponsor* y del *fidepromissor*, ver p. 453.

*
* *
*

9. Un modo de extinción que por diversas aplicaciones clásicas puede enumerarse entre los que obran *ope exceptionis*, pero que en otros casos ya en la misma época podía funcionar *ipso iure*, es la *compensación*. Se la define como "*debiti et crediti inter se contributio*"; y tiene lugar cuando, existiendo entre dos personas deudas y créditos en dirección inversa, el crédito de cada una se reduce en razón del de la contraparte. En el mundo moderno, en que todos los créditos y deudas se reducen al común denominador del incremento y disminución patrimonial, el principio de la compensación es evidente; pero en el sistema clásico, que es sobre todo un sistema de acciones, el hecho de que la fórmula esté redactada con referencia a determinada relación jurídica controvertida, aísla uno de otro a los créditos y deudas particulares, impidiendo su valoración conjunta. La compensación es excepcional y los casos que de ella conocemos son los siguientes:

a) El crédito que se hace valer con un *iudicium bonae fidei* se compensa con las deudas que para el actor derivan de la misma

1917, ps. 114 y ss.); 3) la antigua doctrina permaneció firme durante toda la época clásica para el caso de que la primera obligación naciese de estipulación o de legado; para la compraventa, en cambio, se admitió que el comprador conservase contra el vendedor la *actio empti* para obtener el precio que hubiese eventualmente pagado al tercero, es decir, cuando hubiese adquirido por otra causa onerosa (BESELER, *Contributi*, 4, ps. 326 y ss.). Eje de la discusión es el texto de JULIANO en D. 44, 7, 19, donde los conceptos expuestos por SCHULZ están claramente expresados; que el pasaje esté tan radicalmente corrompido como lo consideran DI MARZO y BESELER, no parece todavía demostrado.

relación deducida en juicio; aunque, en efecto, la fórmula contemple las obligaciones de una sola de las partes, éstas son estimadas *ex fide bona*, y la buena fe no permite valorar la conducta de una de las partes sin tener en cuenta la observada por la contraparte en la ocasión a la cual se refiere la *demonstratio* de la fórmula.

β) Si el banquero (*argentarius*) acciona contra el cliente, debe descontar del crédito que hace valer el importe de los créditos del cliente en su contra (*agere cum compensatione*). Por ejemplo, la fórmula de la *a. certae creditae pecuniae* queda modificada así: SI PARET NM. NM. AO. AO. SESTERTIUM DECEM MILLIA DARE OPORTERE AMPLIUS QUAM AS. AS. NO. NO. DEBET, etc.

γ) El *bonorum emptor*, que adquiere en masa los bienes de un fallido (p. 162), no puede hacer valer los créditos en que ha sucedido a aquél, sin deducir de la *condemnatio* las eventuales deudas del fallido mismo contra el demandado.

δ) Quien, habiendo contratado con un hijo de familia o esclavo en cuyo favor el *pater familias* había constituido un *peculio*, intenta contra el *pater* mismo la *actio de peculio* para que se le pague la deuda en los límites de éste, debe deducir de la *condemnatio* las eventuales deudas (cfr. cap. XIX, § 1) del hijo o esclavo frente al *pater*, pero puede también agregarle los respectivos créditos¹².

ε) Un rescripto de MARCO AURELIO admitió que la compensación pudiera tener lugar también en materia de *condictio*, cuando el crédito que se hiciera valer estuviese en conexión causal con una deuda del actor hacia el demandado. Para alcanzar este resultado, económicamente análogo al ya indicado para los *bonae fidei iudicia*, es necesario que el demandado requiera la inserción de la *exceptio doli*.

Sólo en el derecho justiniano se admite que, por vía de excepciones o también de *mutuae petitiones*, la compensación tenga lugar toda vez que cada una de las partes pueda hacer valer contra la otra créditos válidos, vencidos, de fácil prueba, homogéneos entre sí; solamente en algún caso excepcional esto no se admite en consideración a la persona del actor (fisco, municipios, etc.) o

¹² Sobre la analogía de esta hipótesis con la precedente, cfr. SOLAZZI, *Ius deductionis e condemnatio cum deductione nell' a. de peculio*, en los *Studii in onore di C. Fadda*, 1906. I, ps. 345 y ss.

a la fuente de la obligación (*ex delicto*). En esta época se dice también que la compensación funciona *ipso iure*, máxima de interpretación muy controvertida¹³.

10. Modo típico de extinción *ope exceptionis* es el *pactum de non petendo*, acuerdo entre deudor y acreedor para que éste no requiera el cumplimiento (cfr. p. 393). La institución tiene de común con la *acceptilatio* clásica el fin de remisión de la deuda, pero se distingue de ella porque mientras ésta destruye la obligación en el sentido riguroso del término, aquél sólo proporciona al deudor la base para una excepción (*exceptio pacti conventi*). El *pactum* puede, por lo demás, concluirse también por un tiempo determinado, en cuyo caso sólo sirve para conceder al deudor una dilación (ps. 150 y ss.). En las fuentes justinianeas se distingue el pacto *in rem* del *in personam*; este último se referiría sólo a la persona del deudor, sin extenderse al heredero ni al *fideiussor* (§ 3) ni al codeudor solidario (cap. XIX, § 4); al contrario el *pactum in rem*. Parece que la distinción así establecida es justinianeas, y que para los clásicos el *pactum* aprovechase en todo caso al *fideiussor* como deudor accesorio, no al heredero ni al codeudor solidario¹⁴.

Más bien que un acto jurídico en sí, la *transacción* es un fin que puede estar en la base de estipulaciones, *acceptilationes*, *pacta*, etc.; el fin consiste en poner término a una controversia (litigio presente o futuro) mediante recíprocas renunciaciones a alguna parte de las respectivas pretensiones. Pero el nombre de *transactio* se usa con preferencia cuando dicho fin es alcanzado mediante un pacto, en cuyo caso el derecho clásico sólo admite la acostumbrada *exceptio pacti*; el derecho justiniano reconoce, en cambio, los extremos de un contrato innominado toda vez que uno de los pactantes haya cumplido, y concede a éste contra el otro la acostumbrada *actio praescriptis verbis*.

11. Entre los casos de extinción *ope exceptionis* se incluye la *praescriptio longi temporis*, introducida como extintiva de todas

¹³ Tal es, por lo demás, toda la materia de la compensación, objeto en estos últimos tiempos de amplias investigaciones: cfr. especialmente APPLETON, *Histoire de la compensation*, 1895; BIONDI, "Annali Semin. Giur. Palermo", 12, 1927; SOLAZZI, *Compensazione* (curso litogr. 1927-1928). Mis opiniones sobre algunos puntos entre los más discutidos las he expuesto en el escrito citado en p. 149, nota 19.

¹⁴ Cfr. ROTONDI, *Scritti giuridici*, II, ps. 307 y ss.; SEGRÈ, *Sull'efficacia del p. d. n. p.*, en "Riv. Dir. Comm.", 12, 1914, 1, ps. 1062 y ss.

las acciones *in personam* por una constitución de TEODOSIO II (C. 7, 39, 3) y sujeta al término de treinta años. El treintenio comienza a correr en el momento en que el crédito se hace exigible (por ejemplo, por el cumplimiento de la condición o el vencimiento del plazo), siempre que el acreedor no sea impúber o hijo de familia. La prescripción se interrumpe, aparte que por el pago parcial o por el de los intereses, por el ejercicio de la acción; se suspende si la titularidad del crédito pasa a un incapaz o en tiempo de guerra o semejantes. Alguna excepción al principio de la prescriptibilidad fué eliminada por JUSTINIANO, pero sobre la base del trascurso de cuarenta años. Otra cosa es la caducidad a la cual diversas acciones (por ejemplo, las acciones penales pretorias y las edilicias) estaban sujetas ya en la época clásica, por razones inherentes a la estructura del proceso o a exigencias de seguridad del comercio.

§ 2. TRASMISIÓN DE LOS CRÉDITOS Y DE LAS DEUDAS

El derecho romano excluye que una relación obligatoria se transmita de persona a persona (p. 40); sólo hace excepción, y no para todas las obligaciones (cfr. p. 408), respecto de las sucesiones a título universal, especialmente *hereditas* y *bonorum possessio*.

Este preconcepto teórico no descartaba la necesidad práctica de sustituir, en ciertas relaciones de crédito, una persona por otra. A tal fin sirvió uno de los modos de novación, la *delegatio*; quien quería ceder un crédito ordenaba al deudor que prometiera a otro, en la forma de una estipulación novatoria, lo que a él le debía. Desde el punto de vista jurídico no era ésta una transmisión de crédito, sino la creación de una obligación nueva que sustituía a la antigua; más grave, desde el punto de vista práctico, es que tal resultado sólo podía alcanzarse con la colaboración del deudor.

Un medio más idóneo se tuvo cuando se introdujo la costumbre de que la persona a la cual el acreedor quería ceder la obligación, recibiese de él mandato de obrar contra el deudor; el cesionario se comportaba en este caso como cualquier otro representante (*procurator*), pero por el fin de ventaja propia a que el aparente representante tendía, se acostumbraba llamarlo *procurator in rem suam*. A tal fin servía el principio de la representación indirecta,

en virtud del cual la fórmula llevaba la condena en favor del procurador; así, después de la *litis contestatio* el titular civil del crédito (cedente) no podía ya interponerse entre cesionario y deudor. Subsistía el doble defecto de que mientras el cesionario no hubiese intentado la acción, el cedente habría podido obrar por sí mismo y que con la revocación o con la muerte del mandante (cedente) el mandato se extinguía. Sin embargo, en el derecho clásico el medio descrito tuvo amplia difusión, y sólo para cesiones voluntarias: si dos relaciones jurídicas (entre A y B, y entre B y C) se cruzan en el sentido de que el deudor de uno es acreedor del otro y de que sólo obteniendo de C el cumplimiento, B puede hacer frente a su compromiso respecto de A, el acreedor A puede, obrando contra B, obligarle a ceder la acción contra C; así hemos visto (p. 288) que cuando el titular de un derecho de superficie lo ha cedido a otro, el cesionario puede intentar contra él la *actio empti* con el fin de hacerse ceder la *actio conducti* contra el *dominus soli*, y (p. 392) que todo mandante puede obrar contra el mandatario con la *actio mandati* para hacerse ceder la acción contra el tercero contratante.

Al mero cesionario a título oneroso de una herencia, ANTONINO Pío le otorgó una *actio utilis suo nomine* (es decir, no como procurador, sino en calidad de verdadero titular) contra cualquier deudor de la herencia misma; y en la misma época se admitió que siempre en el caso de cesión onerosa de herencia, el deudor no pudiese ya pagar al cedente cuando hubiese tenido noticia de la cesión producida; esto condujo, como providencia cautelar, al hábito de los cesionarios de denunciar inmediatamente la cesión al deudor. Sobre la base de estas disposiciones y de alguna otra análoga, siempre relativas a casos particulares, el derecho justiniano extendió a todas las cesiones la obligación de la denuncia al deudor, la prohibición de pagar al cedente, la *actio utilis suo nomine* del cesionario.

La cesión puede tener lugar a título de venta, de constitución de dote, de donación, etc.; salvo el último caso, en el cual el cedente responde sólo del dolo, él está obligado a garantizar la real existencia del crédito (*verum nomen*), pero no la efectiva exigibilidad (*bonum nomen*).

El cesionario adquiere el crédito en la misma medida y con las mismas garantías que tenía respecto del cedente. Sin embargo, frente a la práctica, introducida en el Bajo Imperio, de hacer aco-

pio de créditos mal garantidos, comprándolos a bajísimo precio y ejerciendo luego toda clase de apremios contra los deudores, una constitución de ANASTASIO (C. 4, 35, 22, año 506 d. C.) estableció que el cesionario de un crédito a título de compraventa no pudiese pretender del deudor una suma mayor que la pagada por él mismo al cedente. El deudor puede oponer al cesionario todas las excepciones que podía oponer al cedente, salvo las referentes a la persona del acreedor; igualmente pasar al cesionario los *privilegia exigendi*, salvo los inherentes a la persona.

La cesión del crédito puede también estar dispuesta para fines limitados, por ejemplo el de exigir sólo los intereses o sólo el capital; formas especiales de cesión limitada son las conocidas bajo los nombres de usufructo y de prenda de los créditos (cfr. ps. 182 y 292).

En cuanto a la transmisión de las deudas, también fué originariamente actuable en la práctica sólo con una especial estipulación novatoria, llamada *expromissio* (p. 442). También aquí se admitió que un nuevo deudor pudiese subentrar asumiendo el papel de *procurator (in rem suam)*; pero el acreedor no podía ser constreñido a promover la *litis* con tal representante, ni conminarlo a contestarla con la amenaza de las sanciones ordinarias (p. 162); el subentrante quedaba comprometido sólo frente al deudor originario.

§ 3. GARANTÍAS DE LAS OBLIGACIONES (EN ESPECIAL, LAS GARANTÍAS PERSONALES)

Se suele hablar, con diversos significados, de garantía de las obligaciones.

En el sentido más amplio, se acostumbra dar este nombre a relaciones accesorias existentes entre acreedor y deudor y que tienen el fin de ofrecer al primero un medio de coacción para obtener el cumplimiento de la obligación o el resarcimiento del daño. En este sentido se puede llamar garantía al *arrha confirmatoria* (cfr. p. 384); y también la estipulación y la *pecunia constituta* se pueden considerar como garantía, en cierto modo, de la obligación causal a que se incorporan.

En el mismo orden de ideas corresponde recordar la cláusula penal y el juramento. Se da el nombre de cláusula penal a la

cláusula adjunta a la estipulación (practicada sobre todo en las estipulaciones *in faciendo*) con la cual se establece que si el deudor no cumple el compromiso que ha tomado a su cargo, deberá pagar al acreedor cierta suma; la conmutación de la obligación de un determinado comportamiento en la de pagar una suma de dinero tendría lugar, sin más, en definitiva, como efecto del mecanismo procesal de la *condemnatio pecuniaria*, pero la *stipulatio poenae* ofrece la ventaja de eliminar desde el momento de la formación del contrato la incertidumbre respecto de la suma que el juez podría fijar como *litis aestimatio*¹⁵. En cuanto al juramento, que hemos visto desempeñar el papel de fuente de obligación en el *iusiurandum liberti* (p. 358), su función de garantía está atestiguada sólo para el caso del menor de veinticinco años que confirme de este modo una obligación ya contraída; en esta hipótesis, él no puede ya invocar la *restitutio in integrum*, que normalmente corresponde si el negocio, concluido sin la asistencia de un curador, le causa perjuicio¹⁶.

En sentido más estricto, se llaman garantías de las obligaciones las relaciones sobre cuya base el acreedor puede hallar satisfacción, en caso de incumplimiento, o sobre una cosa (*obligatio rei*) o sobre una persona distinta al deudor (*obligatio personae*).

De las garantías reales (*fiducia*, *pignus*, *hypotheca*) se ha hablado ya en varias ocasiones (especialmente en las ps. 291 y ss.); cuanto allí se ha dicho puede ser referido a este punto.

Los tipos de garantías personales conocidos por el derecho romano son: la estipulación pasivamente accesoria¹⁷, el mandato

¹⁵ Para instituciones análogas en el derecho helenístico cfr. BERGER, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden* [Las cláusulas penales en los documentos papirológicos], Leipzig, 1911.

¹⁶ La institución está recordada en una constitución de Alejandro Severo (C. 2, 27, 1); pero parece que precisamente la alusión al juramento deba considerarse interpolada. Las palabras *iureiurando corporaliter praestito* están, en efecto, en el estilo de la cancellería bizantina y de los notarios de la misma época, en la cual los papiros mencionan a menudo un ὄρκος σωματικὸς. Más que considerar interpoladas, como se acostumbra, las dos palabras *corporaliter praestito*, me parece fácil suponer que la institución, de la cual no hay rastros, que yo sepa, en otros lugares de las fuentes, pertenezca a los justinianeos.

¹⁷ La palabra *adpromissio* no se encuentra en las fuentes, en las cuales sólo se habla de *adpromissor* y (siempre para indicar al garante) *accessio*; pero se duda de la claridad de estas expresiones: SOLAZZI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 38, ps. 1 y ss.

del crédito o mandato calificado (*mandatum pecuniae credendae*), el *constitutum debiti alieni* y el *receptum argentarii*¹⁸. A los dos últimos se ha hecho ya referencia (ps. 372 y ss.); corresponde tratar ahora de los dos primeros tipos.

La estipulación pasivamente accesoria ofrece tres formas, según el verbo empleado por las partes (cfr. p. 361): *sponsio*, *fidepromissio*, *fideiussio*¹⁹. Carácter común a todas, en época avanzada, es el de agregarse a otra declaración de obligarse, precedentemente formulada; lo que se expresa formalmente mediante el uso del *idem* (*idem dari spondes?* o *idem fide promittis?* o *idem fide tua esse iubes?*). De esta accesoriedad formal no se deduce, sin embargo, para el derecho clásico, una accesoriedad sustancial, en el sentido de que la obligación del garante esté estrictamente ligada a la obligación principal; por lo menos para la *sponsio* y para la *fidepromissio*, es cierto que ellas son válidas aun siendo nula la obligación a la que deberían acceder; y no siempre las circunstancias que *ex post facto* paralizan la obligación garantizada tienen la misma eficacia sobre la del garante. De todos modos, el garante no puede obligarse *in duriores causam*, es decir, por una suma mayor o por un término menor o incondicionalmente si accede a una obligación condicional; puede, en cambio, obligarse *in meliorem causam*²⁰.

¹⁸ Mucho más amplio es el concepto de *intercessio*, que se podría definir como asunción de obligación en favor de otro; en ella caben, aparte de las garantías personales propiamente dichas, también la novación personal pasiva (*expromissio*, cfr. p. 442) y la asunción de obligación *in solidum* (ps. 470 y ss.) con el fin de favorecer al codeudor. El concepto de la *intercessio* fué elaborado a propósito del senadoconsulto Velleiano (año 46 d. C.), que prohibía las "obligationes feminarum, quae pro aliis reae fierent" (D. 16, 1, 2 § 1). Contra el acreedor que la llame a juicio por tales causas, la mujer goza de una *exceptio S.C.i Velleiani*.

¹⁹ Que el pasaje de GAYO (III, 116) en el cual se alude a estipulaciones de garantía en las formas *idem dabis?*, *idem promittis?*, *idem facies?*, sea un glosema posclásico, es buena conjetura de PEROZZI, *Dalle obblig. da delitto*, etc., p. 27 extr., n. 1 (cfr. BESELER, "Rev. Fundac. Savigny", 53, 1933, p. 19).

²⁰ Sobre los diversos problemas que se agrupan en torno al concepto de accesoriedad véase FLUME, *Studien zur Akzessorietät der römischen Burgschafts stip.* [Estudios sobre la accesoriedad de las estipulaciones romanas de garantía], Weimar, 1932; y DE MARTINO, *Le garanzie personali dell'obblig.*, I, Roma, 1940, caps. v y ss.; LEVY, *Principal and surety in classical Roman law*, en "Seminar", 2, 1944, ps. 6 y ss.

Las tres formas nombradas difieren profundamente entre sí, y no ya por una deliberada búsqueda de diversos medios de eficacia distinta, sino por haber conservado las dos primeras el carácter que les imprimiera el ambiente histórico en que surgieron y por haberse dictado las respectivas leyes reguladoras cuando todavía no se practicaba la *fideiussio*. Pero las diferencias de palabra valen para el derecho antiguo y el clásico; el derecho justiniano ha fundido, aquí como en otras partes, todas las instituciones en una, la *fideiussio*, que no es ya una forma particular sino la denominación común de toda estipulación pasivamente accesoria.

En particular, para el derecho clásico, mientras la obligación que nace de la *sponsio* y de la *fidepromissio* dura sólo un bienio y no se transmite a los herederos, la que nace de la *fideiussio* es perpetua y transmisible. La razón de ello está, probablemente, en caracteres propios de la originaria estipulación (cfr. p. 335, n. 3); de los que la *fideiussio* ha quedado exenta por haber surgido en época más avanzada.

En el tiempo en que *sponsio* y *fidepromissio* eran las únicas formas conocidas, diversas leyes tendieron a regular las relaciones de los garantes entre sí y entre el garante y el deudor principal. Primero una *lex Apuleia* (GAYO, III, 122) dió a aquel entre los varios *sponsores* o *fidepromissores* que hubiese pagado, una acción contra los otros para repetir de cada uno de ellos la parte que habría tenido que pagar si la obligación se hubiese dividido; posteriormente, una *lex Furia* (GAYO, III, 121) estableció que el acreedor mismo debiese obrar contra cada uno de los garantes sólo por su cuota, aunque eventualmente alguno de ellos fuese insolvente, con la sanción de la *manus iniectio pro iudicato* contra el acreedor que no se hubiese ajustado a la norma; en correlación con estas reglas, una *lex Cicereia* dispuso que en el acto de tomar fiadores el acreedor debiese hacer saber a todos ellos cuántos tomaba y por cuáles créditos (GAYO, III, 123). Por otra parte, una *lex Publilia* daba al *sponsor* o *fidepromissor* que hubiese pagado, la *manus iniectio pro iudicato* contra el deudor garantido; en el derecho clásico tiene la misma aplicación la *actio depensi* (GAYO, IV, 22).

A la más reciente de las tres formas de estipulación pasivamente accesoria, la *fideiussio*, no se le aplica ninguna de las normas

citadas; es más: no obstante el carácter de accesoriedad que la forma le imprime, sus reglas parecen en un primer momento elaboradas sobre el modelo de la obligación solidaria (cfr. ps. 469 y ss.). No sólo el acreedor puede dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra el garante, sino que puede elegir uno solo entre los fiadores contra el cual dirigirse por el todo, y éste no tiene siquiera un derecho de compensación contra los otros. El *fideiussor* no tiene tampoco, como tal, una acción de regreso contra el garantido: sólo la jurisprudencia llega a darle una, construyendo poco a poco la asunción de garantía como mandato o como *negotiorum gestio*²¹.

Pero en la época clásica se renueva, a propósito de la *fideiussio* cada vez más ampliamente practicada, aquel movimiento que en las leyes republicanas se había desarrollado para la *sponsio* y la *fidepromissio*. Y, sobre todo, para la división de la obligación entre los cofiadores, un rescripto de ADRIANO, aplicado luego ampliamente por la jurisprudencia, dió al fiador demandado un *beneficium divisionis*, probablemente oponible por vía de *exceptio* (*doli?*) contra el acreedor que llamase a juicio a uno de los garantes por la totalidad del crédito; este *beneficium* se concede, sin embargo, sólo en cuanto los diversos cofiadores sean solventes. Con el fin de poner en todo caso a disposición del fiador que paga, medios judiciales suficientes para obligar al deudor principal a indemnizarlo, se admitió que el acreedor le cediese la acción contra éste (cfr. p. 448), venciendo el obstáculo que para ello derivaba de la producida consunción de la acción (*beneficium cedendarum actionum*).

²¹ Este juego de flujos y reflujos, por los cuales la *fideiussio* habría reproducido, en época avanzada, lo que era el régimen de la *sponsio* y de la *fidepromissio* anteriormente a las leyes citadas, parece verdaderamente singular. No basta para explicarlo la observación de que esas leyes se dictaron con anterioridad al nacimiento de la *fideiussio* misma: muy fácil le habría sido a la jurisprudencia y al pretor extender inmediatamente a la nueva forma el régimen de las ya practicadas. Más bien se podría conjeturar que, como el régimen de la *sponsio* y de la *fidepromissio* había sido construido en relación con la función originaria de la garantía (responsabilidad del garante solamente, con facultad de reembolsarse sobre el garantido), la *fideiussio* haya nacido como accesorio de una obligación principal perfecta en sí misma. Pero no se me ocultan las dificultades a que también daría lugar tal hipótesis.

Pero la consecuencia más decisiva del principio de la accesoriadad fué admitida sólo por JUSTINIANO cuando reconoció al fiador (es decir, según la nueva terminología, a todo *adpromissor*) el *beneficium excussionis*, es decir, la facultad de pretender del acreedor que dirigiese la acción en primer término contra el deudor principal.

Así regulada, la fianza se reduce a la obligación de pagar al acreedor lo que éste no puede obtener del patrimonio del deudor principal. Por derecho clásico, esto ocurría solamente cuando la obligación accesoria era contraída con esta modalidad, caso al cual los modernos dan el nombre de *fideiussio indemnitatis*, mientras que los juristas romanos lo consideraban como una figura completamente distinta de la fianza (cfr. D. 12, 1, 42 pr.; 45, 1, 116). En cualquier otra hipótesis el acreedor era libre para intentar la acción contra el deudor principal o contra el garante, con la consecuencia, sin embargo, de que una vez trabada la *litis* con uno de ellos, no podía ya intentar la acción contra el otro.

En cuanto al respectivo campo de aplicación, mientras la *sponsio* y la *fidepromissio* clásicas acceden solamente a las obligaciones procedentes de estipulación, la *fideiussio* puede acompañar a toda obligación derivada de acto lícito, y no sólo en la época de GAYO sino —a juzgar por el modo como él lo afirma— desde su nacimiento. La máxima se conserva en el derecho justiniano, en el cual, producida la abolición de la *sponsio* y de la *fidepromissio*, puede considerarse regla general de toda garantía personal.

El *mandatum pecuniae credendae* es uno entre los tantos casos de aplicación del mandato; y consiste en el encargo que alguien da a otro de prestar dinero a un tercero. Mientras del préstamo efectuado nace la *actio certae creditae pecuniae* en favor del mandatario mutuante y contra el tercero mutuario, el *contrarium iudicium mandati* puede intentarlo el mismo mandatario contra el mandante cuando el deudor no pague al vencimiento, o cuando, habiendo obrado contra el deudor y obtenido la condena, la ejecución sobre el patrimonio no le haya procurado íntegra satisfacción. También aquí, en consecuencia, depende del arbitrio del acreedor (mandatario) entablar acción primero contra el fiador (mandante) o el deudor (tercero); solamente en pasajes manipulados por los justinianos se encuentra alguna referencia a un *beneficium excussionis*. Pero también aquí corresponde al mandante, si es

demandado en primer término, el derecho de hacerse ceder la acción contra el deudor. Sin embargo, los clásicos distinguen bien la institución en examen de la fianza, y sobre todo ignoran, respecto del mandato de crédito, el *beneficium divisionis*, que los justinianos le extienden por analogía, interpolando D. 27, 7, 7²².

FRANJA
MORADA

²² Cfr. COSTA, *Papiniano*, iv, 1899, p. 28. Sobre la estructura clásica de nuestra institución (exactamente referida al régimen del mandato propiamente dicho) y sobre la tendencia justiniana a fundirla con la *fideiusio*, véase BORTOLUCCI, *Il mandato di credito*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 27, ps. 129 y ss.; 28, ps. 191 y ss.

CAPÍTULO XIX

DE ALGUNOS TIPOS ESPECIALES DE OBLIGACIONES

Hasta ahora hemos considerado la obligación en su estructura normal; y nos la hemos representado dotada de acción, perfectamente determinada en su objeto, contraída mediante acto lícito o ilícito por un solo deudor hacia un solo acreedor, e invariable en esta condición hasta su extinción, aunque fuera eventualmente transmitida de sujeto a sujeto por efecto de sucesión universal o de cesión. Esta exposición debe ser integrada con el estudio de los casos excepcionales en que falta alguna de las características señaladas; en el breve examen que haremos entrarán las obligaciones *naturales*, las obligaciones *genéricas* o las *alternativas*, el problema de la *divisibilidad* e *indivisibilidad* de las obligaciones y finalmente las obligaciones *correales* y *solidarias*.

En los desarrollos que la jurisprudencia romana dedica a estas materias, muy raramente se plantean los problemas en los términos generales en que los plantea la dogmática moderna; antes bien, su consideración se funda casi siempre en casos particulares, especialmente en las diversas configuraciones de la estipulación y del legado *per damnationem*. Es un problema al cual no siempre puede darse respuesta precisa, si esas reglas así establecidas representan —y en tal caso, hasta qué punto— en el mismo pensamiento romano, paradigmas aplicables también a hipótesis análogas.

§ 1. LAS OBLIGACIONES NATURALES

Llámanse obligaciones naturales aquellas relaciones sociales que, no obstante revestir toda la estructura formal de una obliga-

ción y fundarse en una causa por sí misma suficiente para generarla, no están provistas por el ordenamiento jurídico, de un medio judicial o extrajudicial que obligue al deudor al cumplimiento. No por ello estas relaciones quedan totalmente fuera del sistema jurídico; por el contrario, el derecho les ofrece una tutela parcial, sobre todo considerando el eventual cumplimiento como pago, y rehusando, en consecuencia, al deudor la *condictio indebiti* (cfr. p. 402)¹.

El paradigma de la obligación natural está representado en el derecho romano por las deudas y créditos de los esclavos². Ya sabemos (p. 107) que del contrato del esclavo nace un crédito para el amo, y que en algunos casos el amo queda también obligado frente al tercero contratante. Pero, independientemente de tales relaciones entre amo y extraño, que son verdaderas obligaciones, los romanos reconocen entre el siervo mismo y el extraño una relación social análoga a la obligación, a la que da el nombre de *obligatio naturalis*. No podría pensarse en una acción en la que el siervo se hallara pasiva o activamente legitimado; pero, siempre que el obstáculo de la falta de capacidad jurídica pueda ser superado o zanjado, esa relación produce los mismos efectos que una obligación. Así, si el esclavo posee un peculio, el pago por él efectuado en los límites de dicho peculio es plenamente válido y no puede ser revocado ni por el mismo esclavo ni por el amo; igualmente válido es el pago hecho por el esclavo, o el que efectúa el tercero al esclavo después de la manumisión; la obligación del esclavo puede ser garantizada por un fiador, quien, si es un hombre libre, queda civilmente obligado; la prenda constituida en garantía de

¹ En un punto de vista completamente distinto se coloca SIBER (*Naturalis obligatio*, Leipzig, 1925), según el cual el concepto expuesto sería justiniano, mientras que la obligación natural de los clásicos sería la perteneciente al *ius gentium*. Pero esta construcción, que sin embargo figura entre las más doctas y geniales, no convence: se le opone sobre todo, por más esfuerzos que haga el autor (y, concorde con él, ALBERTARIO, *Obbligazioni*, III [Corso di dir. rom.], Milano, 1938, ps. 69 y ss.), el pasaje de GAYO (III, 119 a); y a menudo la exégesis está sofocada por la tendencia a encontrar entre los clásicos, en el uso de las palabras *debitum* y *obligatio*, la contraposición entre deuda y responsabilidad, entre *Schuld* y *Haftung* (cfr. en general, contra la aplicación de esta tendencia al derecho romano evolucionado, ps. 318 y ss.). Cfr. la recensión de LAURLA en "Riv. Ital. Sc. Giur.", nueva serie, 1, 1926, ps. 149 y ss.

² Cfr. GRADENWITZ, *Natur und Sklave bei der naturalis obl.* [*Naturaleza y esclavo en la naturalis obl.*] en los *Festgabe für Schirmer* [Estudios en honor de Schirmer], 1900, ps. 137 y ss.; PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., II, ps. 33 y ss.

la obligación natural, sea por el esclavo si posee peculio, o por el tercero en favor de él, corre la misma suerte que todo derecho de prenda. Respecto del peculio que el *pater familias* asigna al siervo como un pequeño patrimonio de hecho, pueden originarse también entre amo y esclavo relaciones de crédito y deuda; mientras la relación entre ambas partes permanece aislada, no puede hablarse de efectos particulares, ni siquiera del de la *soluti retentio*, porque el amo puede siempre revocar la concesión del peculio o limitarla; pero ya hemos visto (p. 446, letra *δ*) que cuando un tercero intenta contra el amo una acción de peculio, las deudas y los créditos entre amo y siervo adquieren importancia jurídica en el sentido de que el peculio, en cuyos límites responde el amo, se acrecienta con aquellos créditos y se reduce con aquellas deudas. En fin, si el esclavo es vendido con el peculio o manumitido con el peculio, se aplica a todo pago hecho por él la *soluti retentio*.

En todos los casos, es requisito indispensable que entre esclavo y tercero o entre esclavo y amo haya tenido lugar un contrato u otro negocio lícito perfecto, y tal que en cualquier otra circunstancia derivaran de él obligaciones civiles: un mutuo, una compraventa, una estipulación, una gestión de negocios, etc., como las hemos descrito en precedentes capítulos³.

Algo semejante ocurría, por lo menos en el derecho antiguo, con las deudas y los créditos del hijo de familia, tanto respecto de terceros como del *pater* o de otros sujetos a la misma potestad. Pero en este caso, el campo de aplicación de la obligación natural

³ Se ha afirmado (cfr. BONFANTE, *Ist.*, 10ª edic., p. 396) que era necesario un contrato causal; pero esto no está dicho ni en D. 15, 1, 49 § 2 (donde por *nuda ratio* se entiende no ya el contrato literal, sino una anotación relativa a una deuda, cfr. D. 39, 5, 26), ni en la parte genuina de D. 46, 1, 16 § 4; y no hay por qué pensar que, por ejemplo, en materia de estipulación se hicieran especiales distinciones por el hecho de que fuese sujeto pasivo un esclavo. El origen de la falsa opinión está en el hecho de que en las fuentes se habla de *naturalis obligatio* también con un significado diverso, o sea, para distinguir las obligaciones causales de las formales; en este sentido, por ejemplo, es *obligatio naturalis* la que nace del mutuo en antítesis a la que deriva de estipulación. Pero, aunque también este significado de la expresión fuese clásico, sería siempre cierto que nuestros textos no lo confunden jamás con el primero y más técnico. De todos modos, no parece que sea clásico: parecen interpolados D. 5, 3, 31 § 1 (*maxime debebatur*); 12, 2, 42 pr. (VASSALLI); 12, 6, 19 pr. (id.); 36, 1, 61 pr. (BESELER, BIONDI, etc.); 45, 1, 126 § 2 (SEGRÉ, BESELER). En sentido contrario SIBER y ALBERTARIO, citados en la p. 458, nota 1, que precisamente sobre la fe de estos pasajes rechazan la doctrina común de la *obligatio naturalis*.

(si es que se le daba este nombre) fué restringiéndose gradualmente, sea por la capacidad reconocida al *filius familias* para obligarse civilmente, sea porque el desarrollo del régimen de los peculios terminó colocándolo, en la última época, frente a un patrimonio autónomo. El caso que por más largo tiempo conserva un régimen análogo al de las deudas del esclavo es el de las obligaciones contraídas entre los sujetos a la misma potestad.

En la compilación justiniana, la expresión *naturalis obligatio* es ampliamente empleada también fuera de las hipótesis descritas; pero es difícil discernir en qué medida el uso se remonta hasta los clásicos, y en cuál otra hasta innovaciones posclásicas. Estas innovaciones serían en parte meramente teóricas, en el sentido de que bajo el nombre de la obligación natural se habrían subsumido relaciones que ya antes conducían a los mismos resultados que la *soluti retentio* y también a la aplicabilidad de la fianza y de la prenda; pero en parte serían también sustanciales, en cuanto aquella regla de la *soluti retentio* se habría extendido a hipótesis que en el derecho clásico no la admitían. Por lo demás, ni siquiera los justinianos emplearon dicha terminología con toda la amplitud con que lo habrían hecho si hubieran querido dar a la doctrina de la *naturalis obligatio* todo el desarrollo de que era capaz; la difundida nómima de obligaciones naturales que contienen los tratados modernos es, en no pequeña parte, efecto de especulación científica, practicada con particular fervor en ese período de la historia de la jurisprudencia que se conoce con el nombre de *iusnaturalismo* (siglos XVII y XVIII)⁴.

α) De *naturalis obligatio*, o por lo menos de *natura debitum*, se habla respecto de la obligación por la cual el deudor ha sido injustamente absuelto; pero, mientras para la *indebiti solutio* D. 12, 6, 28, no prueba nada, al referirse a un pago espontáneo y no efectuado en la creencia de estar válidamente obligado (cfr. p. 402), el pasaje que sería decisivo (ley 60, pr., h. t.) está mal interpolado justamente en la parte que nos interesa.

⁴ La pérdida que nuestra ciencia ha sufrido con la muerte de PEROZZI, nos ha privado también de la obra que desde hace tiempo preparaba sobre el tema; cfr., sin embargo, aparte de ALIBRANDI, citado en la nota siguiente, también VASSALLI, *Iuris et facti ignorantia* (extr. de los "Studi Senesi", 30, 1914), espec. ps. 27 y ss., y sobre todo, en la parte que no está dominada por los preconceptos señalados en la p. 458, nota 1, el estudio de SIBER.

β) La parte genuina de la ley 60 pr. excluye la repetición como indebido de lo que si un deudor ha pagado después de la *litis contestatio* y antes de la sentencia; pero no porque subsista una obligación natural, sino porque la extinción de tal obligación por *litis contestatio* (cfr. p. 444) tiene un sentido puramente formal, mientras que el proceso que se abre con la *litis contestatio* está precisamente destinado a la satisfacción del acreedor actor.

γ) Cuando una persona *sui iuris*, por adrogación o *conventio in manum*, entra en condición de hijo en otra familia, sus obligaciones dejan de existir por derecho civil. Pero, puesto que los medios arbitrados por la jurisprudencia y por el derecho pretorio ponen siempre al acreedor en la posibilidad de hacer valer su crédito mediante acciones contra aquellos que tienen bajo su potestad a los *capite minuti*, es significativo que en D. 4, 5, 2 § 2, se diga que éstos "*manent obligati naturaliter*"; lo menos que puede decirse acerca de esta frase, es que ella ha sido usada al margen de todo significado técnico.

δ) Para el caso del pupilo que contrate *sine tutoris auctoritate* existe antinomia entre los textos, algunos de los cuales admiten una obligación natural, mientras otros la niegan; tal vez los clásicos no conocían ni el nombre ni la sustancia de la obligación natural, admitiendo una obligación civil en caso de enriquecimiento, y excluyendo cualquier relación cuando faltara el enriquecimiento⁵.

ε) En cuanto a los casos de la obligación extinguida por prescripción y de la obligación emergente de un pacto desnudo, los clásicos admiten indudablemente la *soluti retentio*; pero la construcción de estas especies como obligaciones naturales es, sin duda, justiniana.

ζ) Lo mismo puede decirse respecto del empleo de la terminología de la obligación natural en el caso del mutuo que se pague no obstante haber sido contraído por un hijo de familia contra la prohibición del senadoconsulto Macedoniano; pese a alguna duda planteada recientemente, consideramos que la *soluti retentio* era admitida también por los clásicos, aunque tal vez sólo si el pago era voluntario, en cuya hipótesis servía como ratificación del *pater familias* o del mismo mutuario hecho *sui iuris* (cfr. p. 342).

⁵ Cfr. el escrito póstumo de ALIBRANDI en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 24, 1912, ps. 170 y ss.; contra, SIBER, ps. 43 y ss.

η) Finalmente hay un notable grupo de casos en los cuales, aun no existiendo la obligación jurídica de determinada prestación, ella es impuesta, sin embargo, por conveniencias sociales; así el deber de la mujer *sui iuris* que va a contraer matrimonio, de constituirse la dote, o el del padre de constituirla en favor de la hija *in potestate*; el deber del liberto de prestar servicios al amo aun sin estar obligado a ello por *promissio iurata*; las donaciones remuneratorias, y otros casos semejantes. En todos ellos, la prestación efectuada excluye la *condictio indebiti*, lo que a veces ha decidido a los justinianeos a hablar de *naturalis obligatio*. Es precisamente esta manifestación de la institución la que ha ejercido mayor influencia sobre la posterior evolución doctrinal, y en ella se inspira todavía la referencia a la obligación natural que se hace en el art. 1237 del Código Civil italiano de 1865⁶. Hablando explícitamente de “deberes morales o sociales” y excluyendo todo otro efecto que no sea el de la *soluti retentio*, el art. 2034 del nuevo Código italiano de 1942 ha suprimido las cuestiones a que todavía daba lugar aquella disposición.

§ 2. LAS OBLIGACIONES GENÉRICAS Y LAS ALTERNATIVAS

Entre las obligaciones de dar, es decir, las que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa o de una cantidad de cosas, ocupan un lugar especial las obligaciones genéricas y las alternativas. Tienen como elemento común la imperfecta determinación inicial del objeto, y su determinabilidad en un momento posterior, que puede ser (y normalmente lo es) el del cumplimiento, pero que también puede ser un momento intermedio.

1) Se llama obligación genérica a la que tiene por objeto una categoría más o menos vasta de cosas no fungibles, dentro de la cual deberá ser individualizada la cosa a entregarse⁷.

⁶ Cfr. los tres estudios de BONFANTE nuevamente publicados en *Ser. giur. varii*, III, ps. 1 y ss.

⁷ No es, en cambio, genérica la obligación de dar una cantidad de cosas fungibles, cuando de las cosas a entregarse está indicada la calidad: porque en tal caso la misma fungibilidad hace que la determinación sea la más completa que pueda desearse. En genérica se tornaría solamente si la calidad no estuviera indicada, porque de esta circunstancia procedería la indeterminación (cfr. D. 45, 1, 75 § 1). De ahí la distinción entre

El género dentro del cual debe elegirse el objeto de la prestación puede ser, como ya se ha dicho, más o menos vasto: puedo prometer un esclavo, un esclavo griego, un esclavo griego pedagogo, etc.; o bien un caballo, un caballo árabe, un caballo árabe de tres años. Sin embargo, hay un límite más allá del cual el *genus* sería tan vasto que quitaría al objeto de la obligación toda determinación, y a la voluntad de obligarse toda seriedad; así, si yo prometiese una casa sin determinar su ubicación y su amplitud. A la inversa, hay un límite más allá del cual la obligación dejaría de ser genérica para convertirse en específica (lego a alguien un esclavo etíope de mi familia, y no tengo más que uno)⁸.

Salvo acuerdos especiales entre las partes, la obligación de género se concentra o concreta en determinado objeto sólo en el acto del cumplimiento; en efecto, es regla general que la elección del objeto a entregar la efectúe el deudor. Cuando la elección correspondiese, por convención especial, al acreedor, la concentración se produciría en el momento del requerimiento, judicial o extrajudicial, como ocurre, por ejemplo, cuando *per damnationem* se ha legado a alguien una cosa a elegirse dentro de cierta categoría⁹. Por derecho clásico, el deudor puede entregar o el acreedor reclamar cualquier objeto perteneciente al *genus*; sólo el derecho justinianeo prohíbe al acreedor reclamar el mejor y al deudor ofrecer el peor, ordenando que la elección recaiga sobre cosas *mediae aestimationis*¹⁰.

2) Se llama alternativa la obligación en la cual quedan comprendidas dos o más cosas, o cantidades de cosas, fungibles o no,

las acciones: para las cantidades de cosas fungibles de calidad determinada, se aplica la *condictio certae rei* y respectivamente la *actio ex stipulatu certi* o la *actio certi ex testamento*; para las obligaciones propiamente genéricas, la *actio ex stipulatu* o *ex testamento incerti*. Hay, sin embargo, reglas comunes a las obligaciones genéricas y a las que tienen por objeto cosas fungibles; así, en particular, con relación a la pérdida.

⁸ En cambio, es muy discutido, por una mal conciliable antinomia entre los textos, si, siendo muy restringido el número de las cosas comprendidas en el *genus*, la obligación se transforma en alternativa: sobre el problema cfr. últimamente VASSALLI, *Studi econ.-giur.* Cagliari, 8, 1916, ps. 2 y ss.; DE RUGGIERO, *Obbligazioni* (Corso, 1921-1922), ps. 55 y ss.; BESELER, "Rev. Fundac. Savigny". 45, 1925, p. 233.

⁹ Vale, sin embargo, también aquí la regla especial de la cláusula *quem (o quam o quod) voluero*.

¹⁰ Cfr. últimamente ALBERTARIO, "Riv. Dir. Comm.", 23, 1925, parte 1^a, ps. 177 y ss. (= *Studi dir. rom.*, 3, ps. 374 y ss.).

determinadas sólo en el género o en su individualidad, pero en el sentido de que la obligación se cumpla entregando una sola cosa o cantidad, a elección del deudor, del acreedor o de un tercero que ellos hayan designado de común acuerdo.

Sobre la base de los acostumbrados paradigmas de la estipulación y del legado, como así también del de la compraventa, las reglas vigentes sobre la elección son las que se detallan a continuación. La elección del deudor es normal, salvo el caso del legado, en que la preferencia se concede al legatario acreedor, y tiene lugar siempre que las partes no hayan dispuesto de manera diferente; así como en el caso normal, el hecho de haber comunicado el deudor al acreedor la intención de entregar una de las cosas, y aun el de haber aceptado el acreedor una prestación parcial, no impide al deudor cambiar de intención hasta el momento de la *solutio* total (*ius variandi*), también el acreedor que excepcionalmente tenga la facultad de elegir puede cambiar de opinión hasta el momento en que, llamado a juicio el deudor, conteste la *litis* (*donec iudicium dictet*: D. 45, 1, 112 pr.). Sin embargo, se admitió que el *ius variandi* caducase cuando en la estipulación o en el legado se hubiese agregado a la mención de las diversas cosas la cláusula *quem voluero* (o *volueris* o *voluerit*); en esta hipótesis, el que tiene derecho de elección queda vinculado por la declaración que ha hecho al interesado con anterioridad a la *solutio* o a la *litis contestatio*. En el caso en que la elección se confía a un tercero, la notificación que éste hace a las partes la vuelve irrevocable. Mientras la facultad de elegir pasa a los herederos de la parte a quien compete, no pasa a los herederos del tercero a quien se ha confiado; esto porque se trata de un mandato que, como sabemos, *morte finitur*.

Un problema particular, también relativo al derecho de elección, surge cuando el deudor paga ambas cosas por error; es indudable que él tiene derecho a hacerse restituir una, pero los clásicos dudaban acerca de quién debiese elegirla. La decisión adoptada en el derecho justiniano (C. 4, 5, 10), e indudablemente la mejor, es que la elección de la cosa a restituir corresponde al mismo que tenía la facultad para elegir la que debía entregarse.

Lo mismo que el pago, también la *acceptilatio* de una de las cosas extingue totalmente la obligación alternativa, lo que está conforme no tanto con la función económica de remisión como con la estructura jurídica de pago ficticio que es propia de la

acceptilatio, y que hace absolutamente inconcebible su formulación alternativa. En cuanto al *pactum de non petendo*, la mención que en él se haga de una sola de las cosas comprendidas en la obligación puede perfectamente justificar la duda sobre si se ha querido remitir totalmente la obligación o concentrarla en la cosa restante; esta segunda solución, que es la más conforme con la lógica y con la estructura del *pactum*, parece ser la preferida por la jurisprudencia clásica, por lo menos para el caso en que la elección corresponda al acreedor; JUSTINIANO se remite a la voluntad de las partes, pero prefiriendo, en la duda, la extinción total¹¹.

La pérdida de las cosas comprendidas en la alternativa suscita delicados problemas; según que la pérdida se deba al hecho del deudor o del acreedor o al caso fortuito, y que la elección corresponda al deudor, o al acreedor, o a un tercero, se tiene toda una serie de reglas diversas. El derecho clásico saca las consecuencias lógicas de la estructura disyuntiva de la obligación y de los principios de lo ilícito civil, mientras que el justiniano, con el propósito de evitar en la medida de lo posible, tanto que el acreedor quede insatisfecho como que se quite al deudor el normal beneficio de la elección, ha trastornado en varias partes el sistema. En particular:

a) Si de dos cosas alternativamente debidas, correspondiendo la elección al deudor, éste destruye una, no incurre en acto ilícito, concentrándose la obligación en la cosa supérstite; por consiguiente, si ésta perece también posteriormente, pero por caso fortuito, la obligación se extingue para el derecho clásico. JUSTINIANO acepta la primera solución, pero después de la pérdida accidental de la segunda cosa (la hipótesis contemplada es la de la muerte de un esclavo) otorga al acreedor la *actio doli*: para obtener —según parece— una suma que represente el valor medio entre las dos cosas que habían estado *in obligatione*; con lo que vino a construir una figura singularísima de ilícito eventual, dependiente de un acontecimiento casual sucesivo¹².

¹¹ A esta conclusión llegan SEGRÈ, "Riv. Dir. Comm.", 1914, 1, p. 1070, n. 2, y FRINGSHEIM, *Kauf mit fremdem Geld* [Compra con dinero ajeno], p. 152, n. 4; cfr. finalmente ALBERTARIO, *Corso di dir. rom.*, 1944-1945, ps. 221 y ss.

¹² La ilógica decisión se conserva en el derecho actual; también en el Código Civil italiano de 1942, art. 1290.

b) Si, correspondiendo siempre la elección al deudor, una de las cosas perece por caso fortuito, el conocido principio *casum sentit dominus* hace que para el derecho clásico la obligación se concentre sobre la cosa superviviente. JUSTINIANO admite que el deudor pueda liberarse también pagando la *aestimatio* de la cosa perdida¹³.

También en materia de obligación alternativa se intenta una *actio incerti* (*ex stipulatu* o *ex testamento*) si la elección corresponde al deudor; en cambio, si corresponde al acreedor, éste la ejerce intentando la *actio ex stipulatu* (o *ex testamento*) *certi* por la suma de dinero o *res certa* que prefiera, y obra con la *actio incerti* solamente si la prestación preferida está genéricamente determinada o consiste en un *facere*.

§ 3. DIVISIBILIDAD E INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES

Ya se ha visto (p. 440) que el acreedor no está obligado a aceptar un pago parcial. Pero esta regla rige, en general, cuando y mientras no haya más que un solo acreedor y un solo deudor. En cambio, puede ocurrir que tenga lugar un contrato entre un grupo de acreedores y otro de deudores, o entre un grupo y un individuo, sin que por determinada voluntad de las partes cada individuo esté obligado a pagar o tenga facultad de pretender el todo; la decisión sobre si se puede o no pagar por partes dependerá, en este caso, de que la prestación sea divisible o indivisible. Ocurre más a menudo que siendo, en el momento inicial, uno solo el acreedor y también uno el deudor, uno de ellos muera dejando varios herederos; se aplica en estas hipótesis la máxima (que los juristas hacen remontar hasta las XII Tablas) según la cual las deudas y los créditos se dividen entre los herederos *ipso iure*, pero también esta máxima sólo puede aplicarse en cuanto sea divisible la prestación a que los coherederos tienen derecho o están obligados.

¹³ Sobre el tema (y sobre las interpolaciones de D. 46, 3, 95 § 1, y D. 30, 47 § 3), cfr. SCIALOJA, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 11, 1898, pá. 61 y ss. (= *St. giur.*, 2, ps. 110 y ss.); SCHULZ, *Einführung in das St. der Dig.* [Introducción al estudio del Digesto], Tübingen, 1916, ps. 99 y ss.

Según las fuentes, el régimen elaborado sobre el paradigma de la estipulación es el siguiente:

A) Estipulaciones *in dando*:

α) Si la estipulación tiene por objeto una suma de dinero o una cantidad de otras cosas fungibles, la obligación es divisible, en el sentido de que cada uno de los acreedores puede exigir y cada uno de los deudores debe pagar una cantidad correspondiente a su cuota de crédito o de deuda.

β) Si la estipulación tiene por objeto una cosa fungible individualmente determinada o el usufructo de una de esas cosas, la obligación es igualmente divisible; pero el objeto de la prestación debe ser (salvo acuerdo diverso) no una parte material de la cosa, ni siquiera cuando ésta es materialmente divisible, sino una cuota ideal de propiedad en el sentido que hemos visto al estudiar el condominio (ps. 250 y ss.), o de usufructo. La acción *in personam* (*condictio certae rei* o *actio certi ex stipulatu*) se intenta de todos modos *pro parte*.

γ) Si la estipulación es genérica o alternativa, con elección correspondiente a los deudores, sigue siendo cierto que con relación a una *species* comprendida en aquel *genus* o a una de las cosas alternativamente debidas, cada uno está obligado a transmitir una cuota de condominio, y la obligación, por consiguiente, también es divisible; pero si el acreedor aceptase prestaciones parciales o si la acción (*actio incerti ex stipulatu*) se intentase separadamente contra cada uno de los codeudores, resultaría la incoherencia de que éstos pudieran liberarse dando cuotas de cosas diversas, con lo cual el acreedor no se haría, por ejemplo, dueño de un esclavo sino condómino por una cuarta parte de cuatro esclavos. Para evitar esto, el acreedor debe requerir a los deudores que paguen todos juntos, y en caso necesario obrar contra todos ellos conjuntamente; no será una acción única, sino tantas acciones distintas como deudores, ejercidas acumulativamente y deferidas al mismo juez. En este sentido, y sobre la base de las expresiones de PAULO en D. 45, 1, 2 § 1, la doctrina habla de indivisibilidad *solutione*; ésta desaparece cuando la elección corresponde al único acreedor.

δ) En fin, si una servidumbre ha sido comprendida en la estipulación (o en un legado *per damnationem*), la obligación es indivisible, a causa de aquella indivisibilidad de las mismas ser-

vidumbres de la cual hemos observado otras consecuencias en materia de condominio (p. 252); por eso, la acción se intenta por cada uno de los acreedores y contra cada uno de los deudores por el todo (*in solidum*); es necesario, sin embargo, que en el momento de la constitución de la servidumbre intervengan todos los interesados, y, si *ex parte debitoris* se prefiere pagar la *litis aestimatio*, ésta se pagará *pro parte*.

B) Estipulaciones *in faciendo*:

ε) La *stipulatio operarum* es divisible. En efecto, los servicios que deben prestarse a jornal se consideran cosas fungibles, o más bien, equiparados al dinero; la acción se intenta, en consecuencia, por la parte correspondiente al actor y debida por el demandado.

ς) La *stipulatio operis faciendi* es indivisible como la de la servidumbre, porque una obra inconclusa no se puede considerar económicamente como una porción de la obra concluida. Es probable que en esta hipótesis también la *litis aestimatio* se pague *in solidum* (a diferencia del caso δ).

η) A las estipulaciones *in non faciendo* se aplica el criterio de la divisibilidad o indivisibilidad, según que, por la naturaleza de la omisión prometida, la abstención cumplida por alguno de los deudores represente para el acreedor una ventaja parcial, o la falta de abstención de uno solo quite toda utilidad a la conducta pasiva de los demás. Así, es divisible la estipulación por la cual alguien se obliga a no intentar la *rei vindicatio* respecto de una cosa (si uno de los varios herederos del promitente llega a intentarla, la intentará *pro parte*, y la obligación habrá sido violada sólo por esa parte); en cambio, es indivisible la obligación de dejar pasar por un fundo (porque basta con que uno solo de los herederos del deudor me impida el paso, para que yo esté impedido no parcial sino totalmente). No es éste el lugar para la controversia acerca del modo de hacer valer la obligación indivisible negativa, y sobre los casos en que se la puede hacer valer sólo contra el que dejó de cumplir, o también contra el que cumplió o sólo por aquel de los acreedores respecto del cual no se ha cumplido, etc.

Y ni siquiera es útil insistir sobre otros casos particularmente complejos, que han hecho y hacen de la materia de las obligaciones divisibles e indivisibles una de las más delicadas e

intrincadas; el viejo DUMOULIN (MOLINAEUS) tituló su obra sobre el tema *Extricatio labyrinthi dividui et individui*, pero parece que ni él ni otros lograron seguir hasta el final el hilo de Ariadna¹⁴.

Para regular las relaciones entre el coacreedor que ha recibido la prestación indivisible y los otros, entre el codeudor que ha cumplido y los demás, sirven las acciones que derivan de la relación que los vincula: entre los coherederos el *iud. familiae erciscundae*, entre los socios la *actio pro socio*, entre los condóminos el *iud. communi dividundo*, etc.

§ 4. OBLIGACIONES CON PLURALIDAD DE SUJETOS (CORREALIDAD Y SOLIDARIDAD)¹⁵

La obligación tiene normalmente dos sujetos: un sujeto pasivo, sobre el cual recae la obligación y a quien se da el nombre de deudor (*debitor, reus*), y un sujeto activo a quien compete el derecho subjetivo correspondiente y se le da el nombre de acreedor (*creditor*); en la estipulación, los dos sujetos se designan con los nombres de *reus promittendi* (deudor) y *reus stipulandi* (acreedor).

Las cosas no cambian en las obligaciones con sujeto variable, a las cuales hemos tenido ocasión de referirnos y de las que son tipos principales las obligaciones correspondientes a la *actio aquae pluviae arcendae* y a las acciones noxales (cfr. ps. 196 y ss., 245 y ss., 407 y ss.): aquí el sujeto pasivo se designa por la relación

¹⁴ Cfr. por último el hermoso libro de GUARNERI-CITATI, *Studi sulle obbligazioni indivisibili*, I (Palermo, 1921), y la rápida revisión del tema en BESELER, "Rev. Fundac. Savigny", 46, ps. 89 y ss.

¹⁵ Escritos fundamentales: RIBBENTROP, *Die Lehre von den Korrealobligationen* [La doctrina de las obligaciones correales], 1831; ASCOLI, *Sulle obbligazioni solidali*, en "Studi e Documenti di Storia e Diritto", 11, 1890, ps. 121 y ss.; EISELE, *Korrealität und Solidarität* [Correalidad y solidaridad], en el "Archivio per la Pratica Civile", 77, 1891, ps. 374 y ss.; BINDER, *Die Korrealobligationen im römischen und heutigen Recht* [Las obligaciones correales en el derecho romano y actual], Leipzig, 1899; PERROZZI, *Ist.*, 2ª ed., II, ps. 130 y ss.; BONFANTE, *Il concetto unitario della solidarietà* (en *Scritti giur. varii*, III, ps. 209 y ss.), e *Ist.*, 10ª ed., ps. 385 y ss.; RABEL, *Lineamenti*, ps. 475 y ss.; SEGRÈ, *Corsi di dir. rom.* (Torino), 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924; como así también la literatura citada a propósito del concurso de las acciones (p. 178, nota 47), sobre todo la obra de LEVY y los estudios de BESELER.